Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

La sécurisation fiscale des opérations

1500

Le recours au démembrement de propriété pour l'acquisition et la détention de l'immobilier d'entreprise est une stratégie généralement présentée comme étant source d'optimisation fiscale tant pour l'entreprise que pour ses propriétaires.

L'optimisation est une démarche qui consiste à rendre optimal, c'est-à-dire le plus favorable possible, le fonctionnement d'un système. C'est en réalité ce que chacun fait au quotidien en recherchant le meilleur rapport qualité / prix, la route la plus rapide lors d'un déplacement ou tel produit au meilleur prix. L'optimisation de l'ensemble de ses processus est en outre une ambition constante du chef d'entreprise : optimisation de ses processus de production, de sa rentabilité, de la satisfaction de ses clients, de ses charges et inévitablement de sa fiscalité…

Cette recherche de la voie fiscale la plus favorable est un impératif dans le cadre de l'obligation de conseil auxquels sont soumis avocats, notaires ou experts-comptables. Les sanctions prononcées à leurs encontre ou même à celle de commissaires aux comptes pour manquement à leur obligation de conseil sont légions ; le notaire doit informer les parties sur « l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à [une] opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers » (cass. civ., 1re, 26 janvier 2012, nos 10-25741 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=10-25741&sp=/juri/inca/global/civile/JURI/TEXT/00/00/25/21/66/JURITEXT000025216607.xml&date=2012-01-26), 10-26560 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=10-26560&sp=/juri/inca/global/civile/JURI/TEXT/00/00/25/21/66/JURITEXT000025216607.xml&date=2012-01-26) et 1114.663 ; n° 74 FD), le commissaire aux comptes aurait dû contrôler le bien-fondé d'une exonération d'impôt et de taxes assises sur les salaires (cass. com. 28 mars 2006, n° 04-16659 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=04-16659&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/07/49/68/JURITEXT000007496844.xml&date=2006-03-28), n° 422 FD, X. c/ Y.), l'expert-comptable doit s'assurer de la bonne application du régime de faveur de l'article 210 A en cas de fusion (cass. com. 10 juillet 2007, n° 06-10421 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=06-10421&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/07/53/24/JURITEXT000007532451.xml&date=2007-07-10) (n° 953 FD), Sté Hôtel des Provinces c/ Sté Mutuelles du Mans assurances IARD), etc.

Le législateur lui-même offre enfin au contribuable la possibilité de choisir entre plusieurs formes d'imposition, sous forme d'options, qui n'ont aucune autre motivation que fiscales. Par exemple, l'option à l'IS d'une société civile, l'option à l'impôt sur le revenu d'une SARL ou d'une SAS ouverte par l'article 239 bis AB ou encore l'option pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu, l'option à la TVA en matière de revenus locatifs, etc. Toutes options qui ne peuvent être motivées que par un objectif exclusivement fiscal.

L'optimisation fiscale est ainsi encouragée par les pouvoirs publics. Il n'est qu'à voir les nombreux dispositifs fiscaux – les niches fiscales – proposées aux contribuables leur permettant *d'optimiser* leurs impositions.

L'optimisation fiscale qui rappelons-le, se distingue de la fraude fiscale, est aussi une liberté reconnue par la jurisprudence. *« Un contribuable a le droit de choisir la structure juridique la plus favorable, qui relève de sa liberté d'optimisation fiscale »* (CA Paris 14 mars 2008 n° 06-1770, 1re ch. B, DGI c/ Veluot).

Le choix du chemin fiscalement le plus avantageux est également garanti par une jurisprudence constante et ferme. C'est par exemple le cas lorsqu'il convient de choisir, parmi différentes formules juridiques, entre l'apport en capital ou l'aide directe sous forme de subventions à une filiale (CE 20 mars 1989, n° 56087 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=56087&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/62/89/CETATEXT000007628973.xml&date=1989-03-20), Malet Matérieux ; RJF 5/89, n° 548 avec conclusions Ph. Martin, p. 271), ou entre la cession de parts d'une SCI dont l'unique actif est un terrain à bâtir plutôt que la cession dudit terrain par la SCI (CE 2 mars 1987, n° 51846 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=51846&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/60/81/CETATEXT000007608184.xml&date=1987-03-02) ; RJF 5/87 n° 525).

Le commissaire du gouvernement P. Lobry, dans ses conclusions sur l'affaire de Plénière CE 10 juin 1981 (n° 19-079 ; RJF 9/81, p. 429) indiquait que l'art. 1649 quinquies B du CGI, devenu l'art. L. 64 du LPF réprimant l'abus de droit, *« n'a pas pour objet d'interdire au contribuable de choisir pour l'exercice de son activité économique le cadre juridique qu'il juge le plus favorable du point de vue fiscal [et] ne vise nullement à réprimer l'habileté fiscale des contribuables ».*

Pour autant, *l'habileté fiscale* du contribuable, connaît deux limites, parfois difficile à cerner : le risque d'acte anormal de gestion ou, pire encore compte tenu des sanctions qui s'y attachent, la requalification de l'opération en abus de droit.

Avant d'examiner l'état de la jurisprudence et de la doctrine en matière d'acte anormal de gestion et d'abus de droit, il convient préalablement de rappeler quels sont les enjeux et les motivations d'une opération entraînant le démembrement de l'immobilier de l'entreprise.

Chapitre I - Enjeux et motivations d'une cession temporaire d'usufruit

1501

Comme on a pu le voir dans les précédents chapitre de cet ouvrage, l'acquisition par un chef d'entreprise du bien immobilier ayant pour objet d'héberger son entreprise lui laisse une large palette de choix : inscription de l'immeuble, en direct ou au travers d'une SCI, à l'actif du bilan de l'entreprise ou acquisition par le chef d'entreprise directement ou par le biais d'une société civile, l'entreprise utilisatrice n'étant alors que titulaire d'un bail.

I. Séparer l'immobilier de l'exploitation

1502

Avant même d'envisager d'autres solutions, on peut s'interroger sur l'existence d'un abus dans l'hypothèse d'un recours à une société civile détenue par le dirigeant également propriétaire de son entreprise devenant bailleresse. Une réponse du garde des Sceaux en date du 5 mai 2009 (question de M. Éric Straumann n° 28171, publié au journal officiel le 22 juillet 2008 page 6311, réponse publiée le 5 mai 2009 page 4357) (voir annexe A6) à une question parlementaire écarte un tel risque en tant que tel. Le garde des Sceaux confirme que *« si l'opération semble pouvoir être réalisée dans l'intérêt du dirigeant de la société, elle ne sera pas pour autant forcément contraire à l'intérêt social »* (voir annexe A 6). L'intérêt social de l'entreprise n'est donc pas en conflit avec l'intérêt patrimonial du dirigeant et c'est heureux.

Le souhait patrimonial de séparer le bien immobilier de la société d'exploitation a parfois fait l'objet d'une tentative de redressement par l'administration lorsque des opérations ont été conduites en vue de séparer l'un de l'autre, au meilleur coût fiscal, alors même qu'ils étaient confondus dans la même entité. Ainsi, dans le cas d'un contribuable qui a procédé à une suite d'opérations d'apports et de fusion en vue de séparer l'immobilier de l'exploitation, l'administration a tenté de requalifier ces opérations en cession directe de l'immeuble. La Cour d'appel de Paris (CA Paris 16 septembre 2005, n° 03-8922, 1re ch., sect. B, Cts Logeais) a estimé que *« La succession des opérations réalisées avait pour objectif de faciliter la cession du groupe industriel en séparant l'immobilier des actifs économiques. »*.

L'hypothèse d'une cession en cours de l'entreprise n'est pas indispensable dès lors que le contribuable a pour objectif, dans le cadre d'une gestion patrimoniale prudente de ses biens, de faire sortir du bilan de l'entreprise locataire les actifs immobiliers. La décision Servagent (CAA Lyon 10 février 2005, n° 99-1416, 2e ch., Servagent, RJF 6/05, n° 593, conclusion G. Gimenez BDCF 6/05, n° 80) illustre cette situation. Pour le commissaire du gouvernement, l'objectif de faire sortir les immeubles du bilan de l'entreprise est une *« situation que l'on rencontre souvent qui procède plutôt d'une gestion patrimoniale prudente en cas d'éventuelles difficultés financières, voire même d'ouverture de procédure collective. »*.

Ainsi, le fait de vouloir séparer le bien immobilier de l'exploitation ne peut jamais constituer en soi un abus de droit. Ce choix qui s'offre au chef d'entreprise répond ainsi au souhait de préserver l'immeuble d'exploitation des aléas et du risque de la vie des affaires, de faciliter la cession future de son entreprise sans alourdir son actif d'un bien immobilier, mais aussi de préparer et d'améliorer sa retraite future et de se constituer un patrimoine susceptible d'être transmis à ses enfants sans requérir une compétence particulière de chef d'entreprise.

II. Choisir le régime fiscal applicable

1503

S'il semble acquis pour l'ensemble des raisons exposées précédemment, qu'il est préférable et sans risques de détenir l'immobilier d'entreprise dans une société civile détenue par le dirigeant de l'entreprise, l'éventail des choix offert semble se limiter ainsi au régime fiscal de la société civile : régime de la translucidité fiscale de l'article 8 du CGI ou option ouverte par l'article 239 du CGI pour le régime de l'impôt sur les sociétés (voir Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniale, n° 1-2013, LexisNexis, « Faut-il opter pour l'IS ? », L. Benoudiz pages 20 à 28 pour une comparaison détaillée de ces deux hypothèses). Or, comme chacun le sait, choisir, c'est renoncer.

L'option à l'impôt sur les sociétés recèle cependant d'importantes conséquences tant fiscales que patrimoniales (voir également Pierre Carcelero « L'apport par des personnes physiques à une société soumise à l'IS de parts de SCI peut-il être abusif ? », FR n° 16, 2 avril 2015, EFL). Sur le plan fiscal, elle prive définitivement l'associé de la possibilité de bénéficier à terme, et dans l'hypothèse d'une revente, du régime d'imposition des plus-values immobilières prévu aux articles 150 V et suivant du CGI. Depuis le 31 décembre 2004, la cession de parts de société soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque celles-ci sont à prépondérance immobilière, sont soumises au régime d'imposition des valeurs mobilières prévues par les articles 150 U A et suivants du CGI.

Au-delà de cet aspect fiscal potentiel en cas de cession, le régime de l'impôt sur les sociétés fait peser sur la gestion d'une société civile des contraintes patrimoniales inexistantes si celle-ci bénéficie de la translucidité fiscale. On peut citer notamment la possibilité d'appréhender la trésorerie de la société au fur et à mesure de sa constitution sans devoir attendre la clôture de l'exercice et la mise en distribution d'un dividende ou encore la possibilité de mettre à disposition des associés le bien immobilier détenu à titre gratuit ce qu'interdit, en pratique, le régime de l'impôt sur les sociétés. En outre, l'option étant irrévocable (sauf renonciation dans les cinq ans ouverte par la loi de finances 2019), la liberté de choix accordée aux associés d'envisager un changement de régime fiscal ne peut trouver à s'appliquer. Renoncer définitivement à ces avantages patrimoniaux dans une opération aussi longue et lourde financièrement qu'une acquisition immobilière est une décision difficile.

Enfin, l'organisation du patrimoine à travers une séparation de l'immobilier de l'exploitation, au-delà des avantages patrimoniaux précédemment exploré, a pour effet d'écarter la société d'exploitation de tout arbitrage concernant l'utilisation, la détention ou l'affectation du bien acquis par la SCI.

En d'autres termes, la solution la plus respectueuse de l'intérêt social de l'entreprise serait qu'elle puisse détenir l'ensemble des prérogatives accordées à un propriétaire durant la phase d'exploitation du bien immobilier lui permettant ainsi d'être autonome dans ses décisions concernant son outil d'exploitation (réalisation de travaux, cession, coût d'occupation, etc.). À l'inverse, la solution présentant les avantages patrimoniaux les plus importants pour le dirigeant consisterait à faire détenir l'immobilier dans son patrimoine personnel. Cette contradiction impose en pratique de réaliser un choix définitif, sauf à recourir à la technique du démembrement de propriété.

Le démembrement de propriété des parts de la SCI par cession de l'usufruit temporaire des titres à la société d'exploitation permet de pallier à ces inconvénients, d'éviter de choisir définitivement (et donc, in fine, de renoncer), tout en apportant également de nombreux avantages en matière patrimoniale, économique, juridique et politique. Il faut en effet voir le démembrement de propriété comme étant un partage dans le temps de l'usage d'un bien (voir § 516 (20190730150406293.html#516)). Durant la phase d'activité du chef d'entreprise, la détention de l'usufruit par la société d'exploitation répond à des critères économiques et politiques. À l'âge de la retraite, le chef d'entreprise souhaitera, après avoir transmis son entreprise, disposer de la pleine propriété du bien immobilier afin de garantir ses besoins patrimoniaux.

Il importe cependant de réaliser cette opération en garantissant l'intérêt de l'entreprise à la fois sur le plan économique mais aussi sur le plan juridique.

III. Réaliser une opération économiquement avantageuse

A. Apprécier avec pertinence les avantages économiques

1504

Afin d'apprécier avec pertinence les avantages économiques que peut retirer la société d'exploitation de l'acquisition de l'usufruit temporaire des parts de la SCI, il apparaît comme déterminant d'évaluer la valeur de l'usufruit par actualisation des cash-flows générés par la SCI. Nous ne reviendrons pas en détail sur cet aspect longuement exposé au paragraphe 503 (20190730150406293.html#503). Rappelons qu'il s'agit en l'occurrence de démontrer l'intérêt économique pour la société. Pour cela, il convient de comparer l'impact sur la trésorerie de l'entreprise d'une situation classique où la société d'exploitation est uniquement bailleresse de la SCI d'une situation où celle-ci est non seulement bailleresse mais aussi usufruitière de la SCI. En procédant à cette comparaison, il est alors possible de démontrer l'avantage économique pour la société d'exploitation d'acquérir l'usufruit temporaire des parts de la SCI, dès lors que la somme des flux sur la durée du démembrement est inférieure à celle résultant d'une situation où elle ne serait que locataire ; le coût d'usage est réduit pour la société d'exploitation grâce au démembrement des parts de la SCI.

Évaluer la valeur de l'usufruit par actualisation des cash-flows net est la seule méthode qui permet de s'assurer de l'opportunité de cette acquisition pour la société d'exploitation. Le recours au barème de l'article 669, II du CGI fixant la valeur d'un usufruit temporaire à 23 % de la valeur de la pleine propriété pour chaque période de dix ans ne peut être envisagé sérieusement. Si on retient l'hypothèse d'une SCI constitué avec un capital de 100 000 € et dont le cash-flow net d'impôt prévisionnel est estimé sur les prochaines années à 10 000 € par an, comment peut-on considérer que celui-ci à une valeur vénale de 23 000 €, que la durée de l'usufruit temporaire soit d'un an ou de neuf ans ? Le barème de l'article 669, II ne doit être utilisé que pour le calcul des droits d'enregistrement portant sur la cession de l'usufruit temporaire, la transaction devant être faite à la valeur réelle du droit cédés, calculé par actualisation des cash-flows net.

Procéder en outre à la cession d'un usufruit temporaire en retenant le barème de l'article 669 n'est pas sans poser d'importants problèmes d'ordre comptables, juridiques ou fiscaux. L'évaluation de l'article 669 ne reflétant pas la valeur réelle du droit acquis par l'entreprise, le risque d'une sous-évaluation ou d'une surévaluation est élevé. Les conséquences sont nombreuses : présentation de comptes inexacts remettant en cause la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, abus de bien social, distribution indirecte ou donation déguisée pour ne citer que les principales.

Certains praticiens ont développé une pratique consistant à démembrer dès la création de la SCI avant même que celle-ci n'acquière le bien immobilier.

Cette méthode présente à leurs yeux un avantage déterminant : au lendemain de la création de la SCI, la valeur de l'usufruit temporaire ne peut valoir autre chose qu'une partie du capital social, soit bien souvent pour un démembrement d'une durée comprise entre 10 et 20 ans, une évaluation sur la base du barème de l'article 669, II à 46 % de 1 000 € de capital. La SCI n'est en effet à cette date propriétaire d'aucun bien, n'encaisse aucun revenu et ne supporte aucune charge.

S'il semble en effet difficile de contester cette évaluation, il semble aussi évident qu'il est également impossible de démontrer l'intérêt économique pour la société dans cette hypothèse. L'usufruit sur une durée de 17 ou 18 ans accordé à la société sera-t-il économiquement rentable pour l'entreprise qui, en sa qualité d'usufruitière, va devoir acquitter l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus calculés et très certainement non appréhendé faute de trésorerie par la société ?

En outre, qui accepterait d'acquérir un usufruit sur une société sans connaître la substance de celle-ci, sans connaître les revenus et les charges attendus ? En réalité, cette opération consiste à faire prendre à l'entreprise acquéreuse un engagement sans en mesurer les conséquences et la prive de la démonstration d'un avantage économique à l'opération. S'agit-il pour autant d'un acte anormal de gestion ou d'un abus de droit ? En réalité, rien n'est moins sûr comme le montre la jurisprudence récente ayant eu à se prononcer sur des situations similaires.

B. Les dispositions juridiques doivent refléter les objectifs économiques

1505

S'il est acquis qu'il convient d'actualiser des cash-flows pour déterminer la valeur de l'usufruit temporaire des titres, il importe de limiter les droits de l'usufruitier aux seuls cash-flows et non à l'intégralité du résultat comptable. En l'absence de dispositions statutaires limitant les droits de l'usufruitier *« au résultat comptable dans la limite de la trésorerie disponible à la clôture »*, l'usufruitier détiendra une créance sur la SCI à l'issue du démembrement égale à la différence entre le résultat comptable et la trésorerie distribuable. Or cette créance qui doit pouvoir faire l'objet d'un remboursement à la société d'exploitation n'a pas été valorisée lors du calcul de la valeur de l'usufruit temporaire. La limitation du droit au bénéfice de l'associé usufruitier au montant de la trésorerie disponible à la clôture est-elle envisageable ?

Économiquement, cela ne fait aucun doute : l'usufruitier n'a acquis en pratique, lors de la cession de l'usufruit temporaire, que les cash-flows, soit les résultats disponibles en trésorerie. Lui attribuer plus de fruits ne serait pas cohérent avec la méthode basée sur l'actualisation des cash-flows. Toute autre hypothèse conduirait à une erreur de raisonnement et de calcul. Juridiquement, l'article 1844-1 du code civil stipule que *« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social [...], le tout sauf clause contraire »*. Le code civil permet donc de prévoir dans les statuts une clause limitant le droit aux bénéfices de l'usufruitier à une partie seulement du bénéfice. La seule limite, qui en l'occurrence ne sera pas franchie, consiste à éviter les clauses dites léonines prévus au deuxième paragraphe de l'article 1844-1 *« attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes »* (voir plus en détail infra. § 542).

C. La garantie du coût d'occupation du bien sur une longue période

1506

Enfin, la détention de l'usufruit temporaire des titres de la SCI présente également un autre avantage qu'il semble possible de considérer comme économique bien que son évaluation soit plus difficile à réaliser : la maîtrise sur une longue période, la période du démembrement, du coût d'occupation par la société du bien immobilier loué à la SCI. L'indexation du loyer sur l'indice des loyers commerciaux entraînera chaque année une revalorisation du montant des loyers. Les cash-flows prévisionnels tiennent compte de cette revalorisation sur la base d'une estimation raisonnable de son évolution. Cependant, lorsque le démembrement est prévu sur des périodes pouvant atteindre 20 ou 25 ans, la société n'est pas à l'abri d'une augmentation sensible de son loyer, supérieure à celle envisagée lors de la signature du bail. Il est également envisageable qu'à l'échéance du bail, au terme des neuf premières années, la SCI propriétaire, agissant dans le cadre d'une gestion normale, procède au renouvellement du bail, si celui-ci porte sur des bureaux et non des locaux commerciaux, sous réserve d'une revalorisation déplafonnée des loyers supérieure à la seule évolution de l'ILC. Si la société est usufruitière, l'augmentation du loyer du fait de l'indexation ou du déplafonnement de celui-ci se traduira par un surcroît de revenu, compensant indirectement la charge complémentaire supportée.

En définitive, l'acquisition de l'usufruit temporaire des titres de la SCI garantie à la société d'exploitation un coût d'occupation maîtrisé sur une période longue. Cet avantage économique difficilement quantifiable sauf à recourir à des calculs de probabilités d'une inflation importante des loyers commerciaux, est à elle seule une motivation importante pour la société d'exploitation.

D. La réalisation de travaux par le locataire usufruitier

1507

La garantie d'un coût de détention stable sur une longue période est également un argument déterminant lorsque l'entreprise utilisatrice envisage, ce qui est fréquemment le cas, la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à son exploitation.

L'échéance ordinaire d'un bail commercial de neuf années peut sembler très courte lorsque ceux-ci représentent un investissement lourd. La détention d'un usufruit temporaire garantie à la société d'exploitation une utilisation du bien sur une période bien plus longue dès lors que celle-ci dispose des pouvoirs, en sa qualité d'usufruitière, pour influencer les décisions prises dans le fonctionnement de la SCI.

La prise en charge de travaux par le locataire (qui se trouve être également usufruitier de la SCI lorsque le démembrement porte sur les titres de la SCI) ou par l'usufruitier est appréciée à l'aune de l'intérêt qu'en retire l'exploitant. La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le sort d'une construction nouvelle sur un terrain dont le constructeur détenait l'usufruit. Elle a estimé qu'une telle construction devait être assimilée à une amélioration interdisant à l'usufruitier de solliciter une indemnisation au terme de l'usufruit (cass. civ. n° 11-15460 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=11-15460&sp=/juri/cass/global/civile/JURI/TEXT/00/00/26/39/73/JURITEXT000026397341.xml&date=0002-11-30) ; voir P. Fernoux et M. Iwanesko, « Construction par l'usufruitier : quelles conséquences fiscales au terme de l'usufruit », Dr. fisc. 2016, n° 2, 60).

De la même manière, la décision Tavitian (CAA Lyon 13 juillet 2006, n° 02-873, 5e ch., Tavitian) écarte l'acte anormal de gestion lors du retour gratuit des améliorations lors de l'extinction de l'usufruit en considérant, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 599 du Code civil prévoit que « l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée » et d'autre part, « que l'acquisition de l'usufruit d'un immeuble par une société simultanément à l'acquisition de la nue-propriété du même immeuble par une autre société liée à la première, ne saurait, en soi, constituer un acte anormal de gestion ».

Cependant on peut se demander si l'administration ne pourrait pas considérer, qu'en l'absence de toute demande d'indemnité en fin d'usufruit, l'entreprise renonce à un profit imposable. Au fond, elle n'agirait pas dans son propre intérêt. Le nu-propriétaire a en effet vocation à devenir propriétaire de la construction par voie d'accession au terme de l'usufruit. On pense qu'une telle approche pourrait être soutenue. Cependant, elle ne serait promise à un grand avenir que dans l'hypothèse où il ne serait pas démontré que l'entreprise a tiré un profit suffisant de la construction tout au long de la période couverte par l'usufruit.

Cette analyse n'est pas sans rappeler la jurisprudence concernant le locataire constructeur lorsqu'il s'est agi de savoir s'il commettait un acte anormal de gestion en ne sollicitant pas une indemnité du propriétaire en fin de bail. En l'occurrence, le locataire avait réalisé des travaux de démolition, de reconstruction et de construction sur le bien donné en location alors que le bail prévoyait le retour des constructions entre les mains du propriétaire en fin de bail sans indemnité (CE 10 juillet 1981, req. n° 12864 : RJF 1981, n° 847). Le juge rejeta la prétention de l'administration en se fondant sur les *« avantages tirés par le locataire, dans des proportions satisfaisantes, des travaux ainsi réalisés »*. Il considéra que les dépenses en cause avaient bien été exposées *« dans l'intérêt de l'entreprise locataire »*.

Certes la situation juridique d'un usufruitier ne se confond pas avec celle d'un locataire. Cependant, le parallèle paraît possible. Dans les deux cas, on est en effet en présence d'un constructeur sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et l'on ne voit pas pourquoi un usufruitier qui aurait largement tiré profit de la construction devrait se trouver contraint de demander une indemnité au terme de l'usufruit.

IV. Accorder à l'usufruitier des avantages politiques et juridiques

1508

Là encore, il s'agit de mettre en comparaison la situation d'une société qui ne serait que locataire du bien et celle d'une société qui détiendrait également l'usufruit temporaire des titres de la SCI. Tant les dispositions du code civil (article 1844) que la jurisprudence (Arrêt Gaste, cass. com. 4 janvier 1994, Arrêt Héneaux ; cass. com. 31 mars 2004, Arrêt Gérard ; cass. com. 22 février 2005) (voir infra § 537) permettent d'attribuer à l'usufruitier l'intégralité des droits de vote lors d'une assemblée, le nu-propriétaire, en sa qualité d'associé, ne pouvant être privé du droit de participer aux décisions collectives. Attribuer à l'usufruitier, la société d'exploitation, les droits de vote lors des assemblées permet ainsi de lui donner les pouvoirs concernant le renouvellement du bail, la répartition d'éventuels travaux, le changement d'affectation du bien ou encore sa cession dès lors que les statuts auront pris le soin de prévoir que ces décisions sont du ressort de l'assemblée, limitant ainsi les pouvoirs du gérant.

L'ensemble de ces avantages politiques qui résultent d'une rédaction adaptée des statuts sont également difficiles à quantifier. Ils peuvent par contre être déterminants lorsqu'à l'issue d'une transmission, l'associé de la SCI n'est plus le même que l'associé de la société d'exploitation. L'intérêt social de la société d'exploitation est bien plus protégé que dans la situation où celle-ci ne serait que simple locataire, titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf ans.

Chapitre II - Le risque d'acte anormal de gestion

1509

La description des avantages économiques, politiques et juridiques lorsque l'opération de démembrement respecte les principes précédents écarte définitivement tout risque d'acte anormal de gestion pour l'entreprise (Voir Actes Pratique et Stratégie Patrimoniale, n° 1-2013, LexisNexis, « L'opportunité du démembrement de propriété » S. Anouchian, pp. 29 à 33) ; celle-ci ne subit aucune contrainte et ne profite que des avantages que lui procure son statut d'usufruitière. Pour le garde des Sceaux (réponse Straumann op.cit), en cas de démembrement, il *« conviendra d'analyser le montant de l'acquisition du bien, à la fois par l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'origine des fonds, la durée de l'usufruit, ainsi que les conditions dans lesquelles l'usufruit prendra fin »*, l'intérêt social pour l'entreprise *« dépendra, en réalité, des conditions économiques dans lesquelles seront réalisées les transactions ».* Nul doute que l'intérêt social de la société soit respecté dans cette situation, les conditions économiques étant particulièrement favorables à la société d'exploitation. En matière d'intérêt social, le risque en réalité ne serait-il pas plus important en l'absence de démembrement ?

I. Le risque d'une sur-évaluation ou d'une sous-évaluation des droits démembrés

1510

L'existence d'un acte anormal de gestion reste présente cependant lorsque l'usufruit cédé est soit sous-évalué, soit surévalué, notamment lors de la cession de l'usufruit de l'immeuble. À cet égard, on l'a dit, lors du démembrement, on connaît le rendement de l'immeuble déjà donné en location. En revanche, une donnée fondamentale du calcul de la valeur de l'usufruit reste inconnue : *la valeur de la pleine propriété au jour du démembrement.* À cet égard, le recours à un expert agréé pour réaliser l'évaluation correspondante préconisée dans la première partie de cet ouvrage est un élément de sécurité très important en cas de contrôle de l'administration. Il permet d'éviter une contestation sérieuse par celle-ci de la valeur de l'usufruit.

En effet, pour les besoins du contrôle fiscal, l'administration pourrait s'intéresser à l'évaluation même de la pleine propriété pour vérifier celle de l'usufruit acquis par l'entreprise, lors, par exemple, d'une vérification de comptabilité.

Ce contrôle pourrait faire apparaître une *sous-évaluation* de la valeur de la pleine propriété. Le risque se situerait *au plan des droits de mutation*. La valeur de l'usufruit cédé est *directement liée à celle de la pleine propriété*. Est en effet *égale à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de dix ans sans fractionnement*. En présence d'une sous-évaluation, l'administration pourrait ainsi mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 17 du LPF pour rétablir l'assiette des droits de mutation à ce qu'elle estimerait être sa juste valeur. Elle revaloriserait la valeur fiscale de l'usufruit fiscal cédé. Simplement, pour cela, elle devrait impérativement *procéder par comparaison*. Autrement dit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle devrait, d'abord, rétablir *la valeur vénale réelle des biens immeubles en pleine propriété* en se fondant sur le prix de cession d'immeubles intrinsèquement similaires (voir notamment cass. com. 30 octobre 1989, n° 1266 D : RJF 12/89, n° 1454 ; cass. com. 9 mai 1990, n° 663 D : RJF 7/90, n° 924 ; cass. com. 15 juillet 1992, n° 1325 D : RJF 11/92, n° 1584 ; cass. com. 4 mai 1993, n° 755 P : RJF 8-9/93, n° 1239 ; cass. com. 10 mai 1994, n° 1114 D : RJF 8-9/94, n° 997 ; cass. com. 10 mai 1994, n° 1124 D : RJF 2/95, n° 276 ; cass. com. 26 novembre 1996, n° 1736 D : RJF 3/97, n° 280 ; cass. com. 24 juin 1997, n° 1687 PB : RJF 8-9/97, n° 863 ; cass. com. 21 octobre 1997, n° 2132 D : RJF 3/98, n° 333). L'administration a au demeurant fait sienne cette jurisprudence dans sa documentation (BOFiP-CF-IOR-10-40-§ 150-04/10/2017). Le pourcentage de 23 % par période de dix ans s'appliquerait à cette valeur vénale réelle de la pleine propriété établie par comparaison. Le résultat serait, bien entendu, ensuite soumis au droit de vente d'immeuble.

1511

Cela dit, dans la pratique, c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. Pour recueillir une somme plus conséquente, le dirigeant peut être tenté de surévaluer l'usufruit cédé à sa société. Si l'abus de biens sociaux qu'une telle manœuvre fait encourir ne fait pas frémir le dirigeant, les risques fiscaux et le coût qui s'y attache calmeront à coup sûr les ardeurs de l'apprenti sorcier qui n'entendrait pas bien.

En premier lieu, l'administration procéderait, par ailleurs, à la réintégration de la fraction de l'amortissement pratiqué à raison de la partie surévaluée du droit d'usufruit. Elle en profiterait également pour rejeter *en second lieu*, les frais financiers liés à la partie de l'emprunt correspondante. S'il n'y a que ça, diront les va-t'en guerre, on peut y aller. Attention, les choses prendraient une toute autre tournure si l'administration songeait à mettre en œuvre les principes posés par l'arrêt Thérond (CE, Sect., 28 février 2001, req. n° 199295 : RJF 5/01, n° 620, concl. G. Bachelier BDCF 5/01, n° 67). Pour Gilles Bachelier et Olivier Fouquet, pour que l'on soit en présence d'un acte anormal de gestion :

« Une simple erreur de gestion ou une mauvaise gestion ne suffisent pas. Il faut la conscience d'accomplir une opération ***que l'on sait dépourvue de contrepartie****. Autrement dit,* ***il y a un élément objectif – le montant de l'appauvrissement de l'entreprise – et un élément subjectif – l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de l'entreprise »*** (voir conclusions O. Fouquet sur CE 27 janvier 1989, n° 61422 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=61422&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/07/62/61/CETATEXT000007626131.xml&date=1989-01-27), RJF 3/89, n° 306 ; conclusions Dr. fisc. 25/89 c. 1229).

Nul doute, en effet, que la sous-évaluation du droit cédé ne pourrait être synonyme que d'une libéralité au profit du dirigeant. Comme l'expliquait le Président Bachelier dans ses conclusions sous l'arrêt Thérond :

« Le même raisonnement est transposable pour toute opération d'acquisition ou de cession pour un prix délibérément majoré ou minoré quelle que soit cette opération et quelle que soit la qualité de la partie avec laquelle cette opération est conclue qu'il s'agisse d'un associé, d'un actionnaire, d'un porteur de parts ou d'un tiers. La solution n'a donc pas, en droit, une portée limitée aux seuls éléments d'actif. »

En l'occurrence, sauf à démontrer que la surévaluation lors d'une cession à l'entreprise ou la sous-évaluation lors d'une cession par l'entreprise, serait liée à une contrepartie fournie à l'entreprise par le dirigeant, on voit mal comment celui-ci échapperait à la sanction posée par cet arrêt. Et celle-ci pourrait se révéler très lourde. Aux termes de cette décision, en effet, l'écart de prix acquitté par l'entreprise constitue une libéralité au profit du chef d'entreprise, *imposable entre ses mains en tant que revenu distribué sur le fondement de l'article 111-c du CGI*. L'écart de prix serait ainsi soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, majoré de 25 %, sans le bénéfice de l'abattement de 40 % évidemment.

La Cour de cassation (cass. civ., ch. com. 7 mai 2019, n° 17-15621 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=17-15621&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/38/48/87/JURITEXT000038488748.xml&date=2019-05-07), Sté Harmonie) (voir annexe A15) a récemment eu à se prononcer sur l'effet d'une minoration du prix.

Dans cette affaire, la société Harmonie a cédé au président de son conseil d'administration « une parcelle de terrain décrite dans l'acte de vente comme une parcelle à bâtir moyennant un prix de 2 744 €, alors que cette parcelle était déjà construite au jour de la vente ». La valeur de l'immeuble au jour de la vente a été fixée par la commission départementale de conciliation au prix de 200 000 € que ne contestait plus le contribuable. Le litige soumis à la Cour était d'apprécier si l'écart de prix imposé selon les principes de l'arrêt Thérond précitée, à savoir en revenu distribué sur le fondement de l'article 111, c du CGI écartait la possibilité pour l'administration d'assujettir ce montant aux droits de donation visés aux articles 677, 750 ter et 777 du CGI. La conséquence pour le contribuable n'est pas anodine, la taxation d'une donation entre personnes non parentes, ce qui est le cas entre une personne morale et son dirigeant, étant taxable à 60 %.

Pour la Cour, l'article 902 du Code Civil selon lequel « toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs » n'écarte pas les personnes morales et le barème de l'article 777 du CGI « est également applicable aux personnes morales ». Dès lors, la minoration de prix est une libéralité accordée par l'entreprise à son dirigeant taxable aux droits de donation à hauteur de 60 %.

1512

La taxation aux droits de donation est-elle exclusive de la taxation en revenus distribués ?

Pour Pierre Fernoux (Newsletter n° 318 de l'Aurep : Opérations entre le dirigeant et sa société : les évaluations dangereuses) « l'arrêt Thérond autorise l'imposition du revenu constitué par la libéralité au titre de l'impôt sur le revenu. L'arrêt de la Cour de cassation autorise la soumission de la donation elle-même aux droits de mutation à titre gratuit. La démarche est au fond classique. Par exemple, en matière de vente d'immeuble, l'opération peut être à l'origine de deux impositions différentes, l'une frappant le revenu au travers de l'imposition de la plus-value éventuelle, l'autre la mutation elle-même au titre des droits de mutation à titre onéreux. Inutile ici de se poser la question de savoir si la règle *non bis in idem* serait de nature à faire obstacle à ces impositions au titre de deux impôts différents. Il n'y a en effet pas de sujet. Rappelons simplement que cette règle vise certes à éviter l'application d'une double sanction, mais d'une double sanction pénale à raison d'une même infraction commise par la même personne ».

Ainsi, l'octroi d'un avantage sous forme de minoration de prix entraîne-t-elle à la fois une taxation pour son bénéficiaire en revenu distribué au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux avec une majoration de 25 %, sans le bénéfice de l'abattement de 40 % et une taxation aux droits d'enregistrement à hauteur de 60 %. Pour un contribuable imposé dans la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, la taxation est ainsi en droit à hauteur de 138 % (45 % + 17,2% sur 125 % plus 60 %) du montant reçu, nonobstant les pénalités de 40 % ou même de 80 %...

S'agit-il désormais du risque systématiquement encouru où les circonstances de l'espèce ont-elles déchaîné les ardeurs de l'administration ? Relevons en effet que le contribuable a volontairement menti dans l'acte de cession en déclarant la cession d'une parcelle à bâtir et non d'une construction, qu'il « était un professionnel de l'immobilier et gérant de plusieurs sociétés ayant une activité dans le domaine de l'immobilier et de la construction » et qu'enfin, la minoration de prix est substantielle (2 744 € contre 200 000 € après négociation). L'avenir nous le dira !

Lorsque l'administration corrige non pas une libéralité au bénéfice des associés mais au bénéfice de la société (cession d'un usufruit à un prix inférieur à sa valeur réelle, par exemple) les conséquences sont corrigées entre les mains du bénéficiaire, la société. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1re ch. 15 février 2018, n° 16NT01325 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=01325&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610051.xml&date=02-15)) (voir annexe A7) considère-t-elle que « la SCI LBA avait consenti une libéralité à la société cessionnaire et a rehaussé le montant de l'actif net de celle-ci [...] sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code, en en tirant les conséquences sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2009 ». C'est donc un rappel d'IS pour la société cessionnaire lié à l'enrichissement sans contrepartie dont elle a bénéficié du fait de l'acquisition à un prix minoré d'un actif. En toute logique, la société cessionnaire devrait être en droit d'amortir la nouvelle valeur et récupérer ainsi sur la durée le rappel d'impôt mis à sa charge.

Pour le cédant, la SCI mais surtout ses associés qui sont en réalité ceux qui ont cédé l'usufruit temporaire pour un montant inférieur à sa valeur, l'imposition est, depuis le 14 novembre 2012, automatique par la simple application de l'article 13, 5 du CGI. En effet, « le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant [...] ». C'est donc la valeur vénale qui doit être taxée à l'impôt sur le revenu et non la valeur retenue dans l'acte de cession.

II. La motivation de l'opération et l'intérêt de l'entreprise

1513

Au-delà du risque lié à la surestimation ou sous-estimation des droits cédés, l'opération doit être réalisée dans l'intérêt social de l'entreprise. Deux risques sont identifiables y compris lorsque l'évaluation des droits démembrés a été correctement réalisée.

A. La sortie de la nue-propriété de l'actif du bilan

1514

La sortie de la nue-propriété d'un immeuble ou de parts de SCI inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise doit répondre à un objectif patrimonial ou organisationnel. En cédant la nue-propriété d'un actif, l'entreprise se dépouille irrévocablement d'une plus-value future. La contrepartie de cet appauvrissement est le prix acquitté par l'acquéreur. L'arbitrage opéré par l'entreprise entre d'une part, une nue-propriété susceptible de permettre une plus-value future et une somme d'argent immédiatement disponible peut se justifier pour répondre à plusieurs motivations :

-le souhait d'envisager la séparation des actifs professionnels de l'actif immobilier en vue d'une transmission future de l'entreprise ;

-la nécessité de disposer d'une ressource financière sans avoir recours à l'emprunt ;

-la restructuration du groupe et la réorganisation patrimoniale des actifs du dirigeant.

Le comité de l'abus de droit a eu récemment l'occasion de se pencher sur une succession d'opérations réalisées par un contribuable (séance du 14 février 2019, affaire 2018-23) (voir annexe A13) illustrant cette dernière motivation.

M. X détenait l'intégralité des parts sociale d'une société A, société ayant une activité commerciale propre et locataire d'un bien immobilier détenu par la SCI B, SCI soumise à l'IS détenue par M.X détenant également un local d'habitation loué à un tiers.

Le 23 décembre 2013, la SCI B a cédé l'usufruit temporaire pour une durée de 17 ans à une nouvelle société, C, créée six mois auparavant et détenue par la société A à hauteur de 99,9 % et par M. X pour 0,1 %. Le prix de cession de 587 000 € a été payé comptant et financée par un emprunt bancaire.

La SCI B a ensuite procédé à deux distributions de dividendes : l'une le 26 décembre 2013 à hauteur de 97 000 €, l'autre le 27 mars 2014 à hauteur de 142 600 € payé en nature par l'attribution à M.X de la nue-propriété des biens immobiliers précédemment démembrés.

Le 30 juin 2014, M. X apporte à la société A les titres de la SCI B pour une valeur de 357 000 €, apport placé en report d'imposition de l'article 150-0 B ter.

Le 1er juillet, la SCI B distribue un dividende de 225 000 €, dividendes soumis au régime des sociétés mères et filiales (taxation de la seule quote-part de frais et charges de 5 %).

Enfin, M. X a décidé l'attribution de primes exceptionnelles en complément de sa rémunération à hauteur de 150 000 € en septembre 2014 et de 125 350 € le 1er avril 2015. Pour l'administration, « la mise en place de cette série d'opérations rapprochées dans le temps n'avait été réalisée que dans le but exclusivement fiscal de dégager des liquidités en franchise d'impôt grâce à l'application du régime des sociétés mères dont a bénéficié la société A ».

À l'examen des opérations réalisées, on ne voit pas à quel moment M. X a pu dégager des liquidités en franchise d'impôts... La cession de l'usufruit par la SCI B a entraîné le paiement d'un impôt sur les sociétés par la SCI B tout comme l'ensemble des distributions de dividendes dont il a pu bénéficier qui ont fait l'objet d'un impôt sur le revenu. Il en est à l'évidence de même s'agissant de la prime octroyée qui ne peut avoir échappé à l'impôt sur le revenu.

Ainsi, c'est sans trop de difficulté que le Comité relève que « les différentes opérations concernant les sociétés A et B s'inscrivent dans le cadre de la restructuration du groupe de sociétés appartenant à M. X et qu'elles sont internes à ce groupe. Il constate qu'elles ont été effectuées notamment pour des raisons patrimoniales et estime qu'ainsi le but exclusivement fiscal n'est pas établi ». L'administration s'est rangée à l'avis émis par le comité.

B. L'erreur d'évaluation de l'intérêt économique

1515

L'acte anormal de gestion nécessite *« la conscience d'accomplir une opération* ***que l'on sait dépourvue de contrepartie.*** *Autrement dit,* ***il y a un élément objectif – le montant de l'appauvrissement de l'entreprise – et un élément subjectif – l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de l'entreprise »*** (voir conclusions O. Fouquet sur CE 27 janvier 1989, n° 61422 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=61422&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/07/62/61/CETATEXT000007626131.xml&date=1989-01-27) RJF 3/89, n° 306 ; conclusions Dr. fisc. 25/89, c. 1229).

Dans une opération consistant à acquérir un usufruit temporaire, l'appréciation de l'élément objectif nécessite de s'accorder sur la mesure de « l'appauvrissement de l'entreprise ». À cet égard, le seul critère parfaitement objectif est celui qui consiste à mesurer les effets sur la trésorerie de l'entreprise : quel impact l'opération va-t-elle avoir sur la trésorerie de l'entreprise durant toute la phase de détention de l'usufruit, de son acquisition à son extinction. De ce fait, la méthode de valorisation d'un usufruit temporaire basé sur une actualisation de cash-flows après prise en compte de l'impôt acquitté par l'usufruitier est la seule méthode complète qui permet d'apprécier le risque d'un éventuel appauvrissement.

L'élément subjectif s'apprécie quant à lui au jour de l'opération. L'évolution future des paramètres de l'opération peut entraîner au final un appauvrissement mais celui-ci n'est que la résultante de l'aléa des affaires. Sur ces dernières années, la baisse des taux d'intérêts a permis à de nombreuses entreprises de renégocier en leur faveur le coût de leur crédit, améliorant ainsi la rentabilité de l'usufruit acquis. À l'inverse, des charges non prévues, des litiges inconnus, des retards de livraison, etc. peuvent survenir durant la phase de démembrement et rendre l'opération moins rentable voire même défavorable pour l'usufruitier. Il n'y a pas pour autant d'acte anormal de gestion dès lors où à la date ou l'opération a été faite, les équilibres économiques estimés reposaient sur des hypothèses cohérentes et ne laissaient pas présager d'une future déconvenue.

Il en est ainsi de tout investissement réalisé en vue d'escompter un rendement positif, l'acquisition d'un usufruit temporaire ne déroge pas ainsi à la règle.

Chapitre III - Le risque d'abus de droit

1516

La question de l'abus de droit, s'agissant d'une opération généralement présentée comme source d'optimisation fiscale, se doit d'être posée y compris lorsque l'opération est réalisée avec toutes les précautions précédentes. Relevons en préambule que l'administration elle-même reconnaît la difficulté à qualifier ces opérations d'abus de droit. Le rapport parlementaire rédigé lors de la réforme de l'article 13 du CGI créant un cinquièmement ne cache pas que *« ces situations [...] échappent à la procédure d'abus de droit ». Le ministre délégué à l'économie de l'époque, Jérôme Cahuzac, allait encore plus loin en considérant que ces opérations sont « parfaitement légales en l'état actuel de notre droit ».*

I. L'abus de droit pour fraude à la loi

1517

Telle qu'elle ressort de l'article L. 64, cette fraude suppose la réunion de deux conditions : *« le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs »* et la recherche d'un objectif qui *« n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».*

A. Les textes sont utilisés dans un sens conforme à l'intention du législateur

1518

La qualification d'abus de droit pour fraude à la loi impose de rechercher les objectifs poursuivis par les auteurs de l'article 578 du code civil instituant l'usufruit et promulgué en 1804.

Le démembrement de propriété est une technique juridique consacrée par le code civil. Il peut intervenir au cours de la détention du bien ou *ab initio*. Aucune de ces deux hypothèses n'est étrangère aux intentions du législateur. Aussi, dès lors que les droits démembrés sont correctement évalués et que chacun des titulaires de ces droits respecte les droits et les obligations qui sont les siens, l'utilisation faite du démembrement de propriété est conforme aux intentions du législateur civil.

Aussi, un schéma qui reposerait sur une évaluation totalement fantaisiste des droits démembrés et dans lequel usufruitier et nu-propriétaire ne respecteraient aucune de leurs obligations prévues par le code civil pourrait apparaître comme *purement artificiel*. La fraude à la loi serait très proche au plan fiscal car le caractère purement artificiel du démembrement comporterait des conséquences fiscales dommageables pour le Trésor Public. Et il n'entre évidemment pas dans l'intention du législateur de permettre la mise en place d'un montage purement artificiel.

L'administration aurait, bien entendu, la possibilité de combattre les avantages fiscaux résultant d'une surévaluation manifeste de l'usufruit dans les conditions examinées plus haut en se fondant sur la *théorie de l'acte anormal de gestion*, mais rien ne l'empêcherait de mettre en œuvre l'abus de droit. Elle dispose en effet du choix des moyens pour assurer l'application de la loi fiscale (en dernier lieu : CE, 3e et 8e s.-s., 17 déc. 2010, Req. n° 318048, « SARL Concept Sport » : Droit fiscal 2011, n° 10, comm. 249, concl. E. Cortot-Boucher, Note F. Deboissy).

1519

En ce qui concerne, maintenant, plus spécifiquement les textes fiscaux, ceux-ci sont appliqués dans toute leur rigueur. Les droits d'enregistrement sont bien calculés en fonction de la valeur fiscale du droit démembré objet de la cession. Une éventuelle insuffisance d'évaluation ne relève pas de l'abus de droit. Elle est rectifiable sur le fondement de l'article L. 17 du LPF, comme on l'a expliqué plus haut.

À terme, le chef d'entreprise, ou la SCI, devient plein propriétaire sans avoir à acquitter de droits d'enregistrement, mais ce n'est là que la conséquence de l'application du texte même de l'article 1133 du CGI. Et l'intention du législateur est bien d'éviter le paiement de droits. La reconstitution de la pleine propriété ne résulte, au demeurant, nullement d'une quelconque mutation. À l'arrivée de son terme, l'usufruit s'éteint et n'a donc plus aucune valeur. La logique juridique veut alors qu'aucun droit ne soit perçu lors de la survenance de cet événement.

Dans sa séance du 26 juin 2013, le Comité de l'abus de droit a eu à examiner une opération (affaire n° 2013-12) ayant consisté à céder l'usufruit temporaire d'un immeuble à une SAS préalablement locataire de cet immeuble. La plus-value dégagée lors de cette cession intervenue avant la réforme de l'article 13 du CGI a été intégralement exonérée d'impôt du fait de l'abattement pour durée de détention prévu au I de l'article 150 VC. L'administration soutenait que cette opération avait été réalisée dans le seul but de bénéficier de cette exonération et d'éluder ainsi l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui auraient été perçus sur le loyer en l'absence de cession de l'usufruit temporaire. Le Comité, relevant que *« la cession d'usufruit temporaire a produit des effets économiques et juridiques distincts de la signature ou la poursuite d'un contrat de bail »* (perception immédiate *« d'un prix de cession ferme et définitif et non des loyers échelonnés sur une période de 15 ans »*) a considéré qu' *« eu égard aux effets attachés à l'acte de cession d'usufruit temporaire »*, la SCI ne pouvait être regardée comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal. La décision semble aller de soi tant les effets d'une telle opération sont nombreux : percevoir d'avance, sans risques et en une seule fois une somme significative permet de nombreux arbitrages patrimoniaux que ne permet pas la perception incertaine (compte tenu des aléas des affaires) d'un revenu foncier.

B. Des opérations ne pouvant être constitutives d'un abus de droit… sauf en cas de fictivité ou d'absence d'avantages économiques

1520

Le Comité de l'abus de droit fiscal avait déjà pu examiner en 2016 (CADF, avis n° 2016-11 : Dr. fisc. 2016, n° 41, étude 538, spéc. n° 7. – P. Camelo-Cassan, De l'optimisation à l'abus de droit, la ligne de partage des mots : l'exemple des usufruits temporaires : Dr. fisc. 2017, n° 7, étude 154) le cas d'un apport de l'usufruit temporaire de titres d'une société non soumise à l'IS à des sociétés à l'IS. Dans cet avis, le Comité, rappelant que « l'option d'une société pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit » estime que seule l'existence d'un « montage dans lequel la société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés est dépourvue de toute substance économique » permettrait à l'administration de qualifier l'opération d'abus de droit.

La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16NT04184 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=04184&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/97/62/CETATEXT000036976265.xml&dat 05-31)) (voir annexe A9) retient la même approche en considérant même « que l'existence d'un prix surévalué ne [serait] de nature à établir la fictivité » de l'opération. Le ministre soutenait pourtant que l'opération constituait un abus de droit dès lors « qu'elle relève d'une situation de fictivité juridique du fait de son économie générale compte tenu notamment d'un prix de cession manifestement surévalué, de l'absence d'intérêt économique avéré pour les deux sociétés et de la substitution du droit temporaire d'usufruit au bail commercial alors en cours sans modification significative sur le droit de la SAS d'utiliser l'immeuble pour son exploitation ».

Ces éléments n'emportent pas l'adhésion de la cour administrative d'appel de Nantes qui estime que « le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que l'opération n'a pas eu pour effet de transférer effectivement l'usufruit temporaire de la propriété du bâtiment avec l'ensemble des obligations en résultant dans le cadre de l'acte de cession qui prévoit, notamment la prise en charge par l'usufruitier des grosses réparations ».

Le ministre tentait également d'invoquer l'abus de droit dans sa seconde branche, la fraude à la loi, en considérant que la cession d'usufruit temporaire avait permis de substituer à un revenu foncier imposable au barème progressif une plus-value de cession immobilière exonérée (compte tenu des dispositions à l'époque qui prévoyaient l'exonération après quinze ans de détention), l'article 13, 5 du CGI n'ayant pas encore été adopté à l'époque des faits. Là encore, la cour écarte l'argumentation compte tenu des effets de la cession (perception immédiate d'un prix de cession ferme et définitif et non de loyers échelonnés susceptibles d'être interrompus en cas de cessation d'activité) et de « l'absence d'éléments de nature à établir que le bénéfice [de l'exonération] était contraire aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué cet avantage ».

1521

Encore plus récemment, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4e ch., 11 décembre 2018, n° 17MA02433 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=MA&annee=17&numero=02433&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/37/81/04/CETATEXT000037810464.xml&da 12-11)) (voir annexe A12) procède à la même analyse. Dans cette affaire, le contribuable avait réalisé des opérations de donation, d'apports et de cession portant sur les titres d'une SCI entre le 5 août et le 27 septembre de telle sorte que la SARL, qu'il contrôlait et qui exploitait le bien détenu en crédit-bail par la SCI, détienne l'usufruit des titres de cette dernière. On comprend la motivation fiscale de l'opération lorsqu'on sait que le 13 octobre, la SCI levait l'option d'achat du crédit-bail. Or, en l'absence d'imposition dans le régime de l'IS, la plus-value latente est taxable en raison du changement de régime fiscal de la SCI entraîné par le basculement du régime des BNC vers le régime des revenus fonciers. Du fait de l'application de l'article 238 bis K du CGI, le démembrement permet de maintenir la société dans le champ de l'IS, faisant disparaître ce lourd inconvénient pour les contribuables ; en effet, même en cas d'option possible pour le report d'imposition lors de la levée de l'option, c'est une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu calculé sur la plus-value latente au jour de la levée de l'option qui restera dû au jour de la vente de l'immeuble (voir infra § 14).

Pour l'administration, « ces opérations étaient constitutives d'un abus de droit en se fondant sur la proximité temporelle entre [elles], la sous-valorisation de l'usufruit temporaire des parts de la SCI, les incohérences juridiques résultant de la modification statutaire de la répartition de ses profits exceptionnels et le but fiscal des opérations ».

Malgré le faisceau d'éléments apportés par le ministre, la cour reste concentrée sur la recherche et l'existence d'un avantage économique réel. Ainsi, elle relève que « l'apport de l'usufruit temporaire des parts de la SCI a conduit à un renforcement des fonds propres de la SARL nécessaire à la continuité de son exploitation et que le produit de la cession ultérieure des parcelles a été réinvesti dans l'activité de cette société, permettant d'assurer sa survie. » De ce fait, « l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que les opérations en cause n'ont pu être inspirées par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales des associés de la SCI. »

1522

L'abus de droit peut également être recherché lors de la cession de la nue-propriété d'un immeuble par la société qui en est plein propriétaire.

Tout d'abord, posons un principe juridique simple. Tout propriétaire est en droit de céder un droit démembré portant sur le bien qu'il possède. L'important est de le faire dans des conditions respectueuses des principes, et notamment des principes d'évaluation. Toute tentative visant, par exemple, ici, à sous-évaluer la nue-propriété pourrait amener l'administration à penser que le montage comporte en fait un artifice dans le but de masquer la réalité de la situation, toute chose nécessairement étrangère à l'intention du législateur.

À cet égard, la cession de la nue-propriété est souvent faite au profit d'une SCI constituée par le chef d'entreprise. On rappelle ici la nécessité exposée dans la stratégie I de faire impérativement fonctionner cette société et de lui donner une vie active (voir § 1204).

À cet égard, on a vivement recommandé de réaliser des apports en numéraire au profit de la SCI NP. Depuis les décisions Pléiade (CE 18 février 2004, Req. n° 247729 : RJF 5/04, n° 510, concl. P. Collin BDCF 5/04, n° 65, obs. N. Chahid Nouraï BGFE 3/04 p. 17, note J.-Cl. Parot Petites Affiches 9 juillet 2004, n° 137, p. 17, Mme C. Acard Banque et Droit, n° 95, mai-juin 2004 p. 65 et Sagal ; CE 18 mai 2005, Req. n° 267087 : RJF 8-9/05, n° 910, concl. P. Collin BDCF 8-9/05, n° 110, obs. N. Chahid-Nouraï : BGFE 4/05), on sait que toute société doit avoir une *substance autre que fiscale*. De tels apports, dont il n'est pas nécessaire qu'ils soient excessivement importants, permettent de réaliser des investissements en pleine propriété productifs de revenus.

Pour autant, lorsque la nue-propriété est détenue par une SCI, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit, tel qu'il était dénommé à l'époque des faits qui lui étaient soumis, voyait dans l'absence de revenus un critère permettant de prétendre que la société n'a pas de *fonctionnement réel* (rapport pour l'année 2003, avis nos 2001-6, 2003-20 et 2003-23 ; rapport pour l'année 2004, avis nos 2004-9 et 2004-16).

Il est même allé plus loin dans son rapport pour 2006 (BOI 13 L-1-07, Avis n° 2005-6). Même si le schéma condamné par le comité reposant sur l'apport de la nue-propriété d'un immeuble à une SCI suivi de la donation des parts de la SCI était différent de celui étudié ici, il reste que les motifs évoqués par le comité laissent planer un doute. On lit en effet :

« Il constate (le comité) par ailleurs que, lors de sa constitution en 2001 et au cours des trois années suivantes, la SCI ne disposait ***que d'un patrimoine en nue-propriété*** *et corrélativement* ***d'une absence complète de ressources, situation ne lui permettant ni d'assumer les charges de la propriété, ni de répondre aux objectifs assignés par l'article 1832 du Code civil à tout contrat de société****. »*

La référence à l'article 1832 du code civil pourrait faire craindre que les associés de la SCI nu-propriétaire puissent être considérés comme n'ayant pas la volonté de réaliser des bénéfices ou de profiter d'une économie. La société ne dispose, en effet, pas de revenus. Autrement dit, celle-ci serait en quelque sorte fictive pour ne pas répondre à la définition du contrat de société. Et si elle était fictive, cela remettrait en cause le démembrement dans son entier. On a tordu le cou à cette idée pour le moins ignorante de la réalité économique depuis bien longtemps (« SCI et démembrement de propriété : contribuables… résistez », Droit et patrimoine, mai 1998, pp. 29 et s.).

La conclusion du comité, dont on souligne le décalage par rapport aux analyses actuelles du Comité de l'abus de droit fiscal présidé par Gilles Bachelier, paraît mal fondée. En vérité, *rien n'est en effet plus profitable qu'une société nu-propriétaire*. En effet, la valeur de la nue-propriété ne fait que s'accroître au fil du temps, dans l'exacte proportion de la diminution de celle de l'usufruit. Cette augmentation de valeur de la nue-propriété doit au demeurant être constatée chaque année dans le bilan de la SCI à qui l'on conseille la tenue d'une comptabilité de type commercial. Cela permet en effet de matérialiser clairement le profit réalisé et donc l'augmentation mécanique de la valeur des parts détenues par les associés. Aucune taxation n'accompagne cet écart de réévaluation dans une société dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, cependant qu'une éventuelle plus-value relève du régime des plus-values des particuliers de l'article 150 U du CGI.

À ce profit journalier, s'ajoute celui constaté à *l'extinction de l'usufruit*. Ainsi, lorsque la pleine propriété des locaux professionnels est à terme reconstituée au sein de la SCI, l'associé s'enrichit de manière très conséquente. La société détient un bien susceptible d'être exploité au travers d'une location. Autrement dit, l'associé est non seulement certain de s'enrichir, mais également de recueillir des bénéfices à terme. Et ceux-ci peuvent être plus que conséquents lorsque l'on connaît le rendement d'un immobilier d'entreprise. Il est donc bien animé par la volonté de réaliser des bénéfices, répondant ainsi aux objectifs assignés au contrat de société par l'article 1832 du code civil.

Quant à la difficulté dans laquelle serait la société de faire face à ses propres dépenses, on formulera trois observations. *En premier lieu*, si le nu-propriétaire est effectivement en charge des dépenses de l'article 606 du code civil, on a rappelé en première partie que l'usufruitier ne peut le contraindre à les financer. *En second lieu*, pour subvenir aux besoins financiers de la société nu-propriétaire, on ne voit pas ce qui interdit à l'associé de procéder à des apports en compte courant. C'est même un moyen assez classique de financement d'une société qui rencontre des difficultés de trésorerie. La tenue d'une comptabilité commerciale permettrait d'attester alors, de manière certaine, de la réalité et du quantum de ces apports.

Enfin, on remarquera qu'admettre l'abus de droit au motif que les associés n'ont pas la volonté de réaliser un profit conduirait à remettre en cause d'autres schémas, et notamment celui qui consiste à détenir une habitation principale dans une société de gestion patrimoniale. Or, cette problématique a été traitée en son temps par la Cour d'appel de Bourges (CA Bourges 12 mars 2001, n° 99/00456 « Lumet » ; P. Fernoux, SCI et démembrement de propriété : contribuables… poursuivez la résistance : Droit et patrimoine, n° 92, avril 2001, pp. 33 et s.). Dans cette espèce, l'administration avait mis en œuvre l'abus de droit parce que l'apport à une SCI portait sur la nue-propriété de l'habitation principale de l'apporteur. Elle estima :

*« Qu'en effet les sociétés civiles immobilières ont généralement pour objet la conservation et la gestion de biens immobiliers et q****ue n'exerçant pas d'activité commerciale, elles n'ont pas vocation à réaliser des profits****.*

Qu'il ne saurait donc être fait grief à la société Y… une absence de recettes ou de charges*, l'immeuble qui lui a été apporté et qu'elle a pour objet de gérer constituant la résidence principale de PB. »*

Dès lors, le montage ne présente pas un caractère purement artificiel et les textes mis en œuvre le sont dans le respect des intentions de leurs auteurs. L'élément objectif de la fraude à la loi fait, par conséquent, défaut.

Au terme de cette stratégie :

-l'usufruit est conservé par l'entreprise. Durant toute la période couverte par l'usufruit, elle conserve par conséquent le contrôle de l'usage des locaux. Financièrement, cette solution permet par ailleurs d'alléger ses propres charges. La cession lui permet de recueillir le prix correspondant. Celui-ci peut être utilisé, par exemple, à entretenir l'immeuble, à financer des travaux importants de remise en état ou d'adaptation des locaux, ou encore à rembourser un emprunt par anticipation ;

-la cession de l'entreprise à terme en est facilitée du fait de l'absence de tout immeuble à l'actif du bilan à l'issue de la période couverte par l'usufruit ;

-le chef d'entreprise se ménage la constitution future d'un patrimoine familial utile au financement de sa retraite future, par exemple.

Tous ces éléments permettent de soutenir que la stratégie retenue est étrangère à toute volonté exclusive d'éluder l'impôt. Au demeurant, on remarque qu'elle n'est pas sans engendrer de coûts fiscaux. Ainsi en est-il déjà lors de la cession de la nue-propriété. L'entreprise cédante va devoir acquitter l'impôt correspondant à la plus-value constatée à la date de la cession. Le chef d'entreprise, ou la SCI acquéresse, devra, lui, acquitter des droits de mutation à titre onéreux conséquents tout autant que la TVA si la cession est soumise à cette taxe.

C. Une substance économique qui doit être tangible, notamment en termes de flux financiers

1523

Il ne faut cependant pas oublier que la substance économique de l'opération, l'avantage économique pour la société, qui détiendra l'usufruit temporaire, doit être bien réel ; les juges appréciant cette réalité au regard de la trésorerie effectivement appréhendé par l'usufruitier. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1re ch., 3 novembre 2011, n° 10VE02186 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=VE&annee=10&numero=02186&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/24/80/20/CETATEXT000024802015.xml&dat11-03)) retient-elle, dans un arrêt du 3 novembre 2011, l'abus de droit lorsque la cession d'usufruit temporaire n'emporte que des conséquences comptables et fiscales, sans mouvements financiers. Dans cette affaire, « les bénéfices de la SCI ont été effectivement comptabilisés au compte courant de la société usufruitière » mais « la trésorerie de cette société n'en a pas pour autant été améliorée en l'absence de virement financier ». De même, la « cession en cause n'a généré aucun flux financier au profit du [cédant] dès lors que le prix de la cession d'usufruit temporaire est demeuré inscrit sur son compte courant ». Ainsi, c'est un simple jeu d'écritures comptables, sans mouvements financiers, qui a permis d'exonérer in fine les résultats de la SCI compte tenu des déficits fiscaux que détenait la société usufruitière.

La Cour d'appel de Paris, dans une décision bien plus récente (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 3 avril 2018, n° 16/06257 : JurisData n° 2018-006494 - V. J.-F. Desbuquois, Sélection de décisions des tribunaux de grande instance et des cours d'appel : Dr. fisc. 2018, n° 27, étude 319, spéc. n° 4) confirme l'analyse réalisée par le Comité de l'abus de droit le 22 novembre 2012 (Aff. 2012-29, in Comité de l'abus de droit fiscal : rapport. annuel 2012 : Dr. fisc. 2013, n° 27, étude 357, spéc. n° 13) dans une affaire où les contribuables avaient cédé l'usufruit temporaire des titres d'une SCI à une société civile agricole (SCA) propriétaire d'un château et de terres pour une durée de dix ans. Pour l'administration, il s'agissait d'un montage destiné à faire disparaître de l'assiette de l'ISF des contribuables 80 % de la valeur des parts de la SCI, les associés de la SCA ne déclarant que la valeur de l'usufruit d'une durée de dix ans des parts de la SCI inscrit à l'actif de celle-ci. Pour le contribuable, l'apport de l'usufruit temporaire avait principalement pour objectif de faire face au financement de travaux de réhabilitation du château ayant fait l'objet d'une ouverture de crédit de 77 224 €. Pour la cour, le caractère fictif de l'opération résulte de plusieurs éléments : les contribuables se sont réservé la jouissance de trois appartements sur les 52 que détient la SCI sans que l'acte d'apport de l'usufruit temporaire ne l'envisage, les loyers sont perçus pour le reste de l'immeuble par une société civile dont la totalité des parts est détenue par les apporteurs et enfin, les associés appréhendent la quasi-totalité des revenus produits puisque la SCA ne procède à aucun investissement pour son propre compte.

Dans cette affaire, ce n'est pas la fictivité du montage qui est mis en cause, les revenus de l'immeuble ont bien été perçus par la SCA et l'opération a eu des effets économiques indéniables, la SCA percevant grâce à cette cession temporaire des revenus *« plus de trois fois supérieures au montant des travaux »*. Le Comité a, par contre, estimé que les avantages économiques allégués n'étaient ni suffisants, ni déterminants.

C'est bien évidemment ce dernier argument qui est décisif. Pour la Cour d'appel de Paris, il ne suffit pas qu'il existe des flux financiers, encore faut-il que ceux-ci soient utiles voire nécessaire au détenteur de l'usufruit des parts de la SCI compte tenu du fait que les contribuables n'ont pu, en l'espèce, justifier d'aucun autre intérêt patrimonial, juridique ou économique pour la SCA.

1524

La Cour Administrative d'Appel de Douai a eu l'occasion récemment (CAA Douai, 4e ch., formation à 3, 1er juillet 2019, n° 17DA01029 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=DA&annee=17&numero=01029&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/38/72/28/CETATEXT000038722898.xml&dat 07-01)) (voir annexe A17) de rappeler à l'administration qu'une acquisition en démembrement ne pouvait être, en tant que tel, une opération constitutive d'un abus de droit ou d'un acte anormal de gestion, quand bien même celle-ci présente des avantages fiscaux indéniables, dès lors que l'opération n'est pas fictive.

Monsieur C. a créé, avec son épouse, une SARL dénommée Thierry C ayant pour activité la culture de pommes de terre. Celle-ci s'est portée acquéreuse de l'usufruit des parts d'une SCEA et d'une SCI pour une durée de 21 ans et pour une valeur d'acquisition représentant 65 % de la valeur de la pleine propriété. La nue-propriété de la SCEA et de la SCI ont été acquis en direct par M. C et son épouse.

En conséquence de cette structuration, la société Thierry C a pu comptabiliser chaque année des amortissements sur l'usufruit des titres de la SCEA et de la SCI tout en déduisant les charges financières supportées par le financement de ces acquisitions. En contrepartie de ces dépenses, la SARL Thierry C remontait dans ses comptes les revenus provenant de ses usufruits.

L'administration y a vu à titre principal un abus de droit et à titre subsidiaire, un acte anormal de gestion et avait ainsi refusé la déduction de l'amortissement de l'usufruit sur les titres et les charges financières de l'emprunt. La Cour, constate, dans un premier temps, « que l'acquisition pour une durée de vingt-et-un an de l'usufruit temporaire des parts de la SCI C... et de la SCEA C... par la SARL Thierry C... a été réalisée par actes notariés du 14 janvier 2009 dont la réalité et les effets ne sont pas contestés ». Qu'en outre, « les SARL Thierry C..., la SCI C... et la SCEA C... sont le support d'activités économiques réelles et que la SCEA C... et la SCI C... ont au cours des années en litige versé à la SARL Thierry C... des revenus au titre de l'usufruit temporaire qu'elle avait acquis. » Compte tenu de ces éléments, la conclusion s'impose : « Par suite, il n'est pas établi que l'opération de démembrement de la propriété des parts de la SCEA C... et de la SCI C... et l'acquisition de l'usufruit temporaire de ces parts par la SARL Thierry C... constituerait un montage purement artificiel et fictif. »

Si l'abus de droit pour fictivité est rapidement écarté, l'opération peut-elle être sanctionnée pour fraude à la loi ? C'est ce que cherchait à démontrer l'administration mais sans réussir à trouver avec pertinence l'article du CGI qui aurait été abusé... Celle-ci s'est donc rabattue de manière surprenante sur un article du code civil, laissant la Cour assez dubitative sur cette argumentation : « D'autre part, l'administration fiscale soutient que la SARL Thierry C... a recherché l'application littérale des dispositions de l'article 619 du code civil, selon lesquelles l'usufruit temporaire concédé à une personne morale ne peut excéder trente ans, à l'encontre de l'intention de leurs auteurs. Toutefois, de telles dispositions, en elles-mêmes, n'ont aucun objet ni aucune portée fiscale et ne sauraient en conséquence être utilement invoquées par l'administration pour démontrer l'existence d'une fraude à la loi fiscale qui suppose l'utilisation de dispositifs fiscaux à l'encontre de l'intention de leur auteur. Par suite, l'administration fiscale, qui n'invoque aucune disposition fiscale dont la SARL Thierry C... aurait recherché une application littérale à l'encontre des intentions de ses auteurs, en ayant recours au mécanisme de l'usufruit temporaire prévu par les dispositions de l'article 619 du code civil, n'établit pas l'existence d'un abus de droit. Ce seul motif suffit à lui seul pour écarter l'existence d'un abus de droit dans l'opération en litige. »

Afin d'éviter tout regret à l'administration qui aurait certainement dû invoquer plutôt l'article 238 bis K du CGI que l'article 619 du Code civil, la Cour prend la peine de compléter son argumentation en précisant « qu'en tout état de cause, si la SARL Thierry C... a pu, grâce à l'opération d'acquisition temporaire d'usufruit des parts de la SCI C... et de la SCEA C..., procéder à l'amortissement de la valeur totale de l'usufruit et déduire en tant que charge les intérêts de l'emprunt souscrit pour procéder à cette acquisition, il résulte toutefois de l'instruction que ces déductions fiscales ont une contrepartie dans la perception de revenus versés par la SCI C... et la SCEA C.... Si la SARL Thierry C... avait acquis directement les parts de ces sociétés en pleine propriété, elle aurait pu également déduire les intérêts d'emprunt liés à cette acquisition. Par ailleurs, si l'administration fiscale soutient que la taxation à l'impôt sur les sociétés des revenus versés par la SCI C... et la SCEA C... est plus avantageuse qu'une taxation à l'impôt sur le revenu et que l'opération entraîne une absence de taxation des revenus à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au nom de M. A... C..., il résulte de l'instruction que même si elle avait acquis les parts en pleine propriété, les revenus afférents à ces parts que la SARL Thierry C... aurait perçus auraient été imposés à l'impôt sur les sociétés.

L'argumentation développée par la Cour remet les pendules à l'heure ! Le fait que les droits soient démembrés ne suffit pas à considérer qu'il y a abus car les mêmes effets auraient pu être obtenus par une détention de la pleine propriété des titres sans pour autant encourir les foudres de l'administration. Or, l'existence de droits démembrés laisse le contribuable libre de choisir la répartition de ces droits comme il l'entend, dès lors que l'intérêt des parties, l'équilibre économique de l'opération, est respecté.

La Cour prend également la peine de justifier les raisons qui ont conduit le contribuable à céder l'usufruit et non la pleine propriété des titres à la SARL Thierry C. « La SARL Thierry C... fait valoir, sans être contestée sur ce point par le ministre de l'action et des comptes publics, que si elle avait acquis les parts de la SCEA C... en pleine propriété, la SCEA C... n'aurait alors pu se voir apporter par M. et Mme C... les terres agricoles pour lesquelles ils sont preneurs d'un bail rural en raison des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural qui prévoit cette mise à disposition à la condition que le capital de la SCEA soit majoritairement détenu par des personnes physiques. Ainsi, la SARL Thierry C... avait un intérêt autre que fiscal à n'acheter que l'usufruit des parts de la SCEA C.... En conséquence, le choix de la SARL C... de n'acquérir que l'usufruit temporaire des titres de la SCI C... et de la SCEA C... répond indépendamment de l'économie fiscale qu'elle lui procure en lui permettant de déduire l'amortissement de l'usufruit, à une préoccupation de nature économique afin de permettre à la SCEA C... de pouvoir bénéficier de l'apport des terres des époux C... dont ils sont locataires. Par suite, nonobstant l'avantage fiscal qui en découle, l'administration fiscale ne démontre pas que l'opération en cause procède, pour la SARL C..., de la recherche d'un but exclusivement fiscal.

À titre subsidiaire, l'administration cherchait à redresser la SARL Thierry C sur la base d'un acte anormal de gestion aux motifs « que la SARL Thierry C... a financé par emprunt l'acquisition de l'usufruit des parts de la SCI C... et de la SCEA C... alors même que dans vingt-et-un ans elle perdra les fruits liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie. À l'issue de ce délai de vingt-et-un ans, calculé sur la durée de l'activité agricole de M. C..., ce dernier sera propriétaire des parts de la SCI C... et de la SCEA C... dont l'acquisition aura été financée à 65 % par la SARL Thierry qui en aura supporté les frais financiers et ne percevra aucune contrepartie. »

Aucun de ces arguments ne convainc la Cour qui estime « que l'usufruit acquis par la SARL Thierry C... ne pouvant être que temporaire, elle pouvait légalement l'amortir, l'administration fiscale ne contestant d'ailleurs pas dans son principe cet amortissement ni sa durée. En outre, il n'est pas établi par l'administration fiscale que l'abandon au terme du délai de vingt-et-un ans, de l'usufruit au nu-propriétaire constituerait une intention libérale de la SARL Thierry C... au profit de son gérant dès lors que ce dernier a

renoncé aux fruits des parts dont il est propriétaire pendant vingt-et-un ans au profit de la SARL Thierry C.... Par ailleurs, si l'administration fiscale fait valoir que l'amortissement pratiqué aurait été calculé de manière à compenser exactement les produits issus de l'usufruit, elle ne l'établit pas. Les produits issus de l'usufruit n'ont pas vocation à être fixes ainsi que le montrent les résultats affectés à la SARL Thierry C... à proportion de ses parts au cours des années en litige. L'administration fiscale n'établit pas non plus que le montant de l'usufruit temporaire des parts en cause pendant vingt-et-un ans devrait représenter moins de 65 % du prix d'acquisition de ces parts. Enfin, les frais financiers en litige ne sont pas dénués de contrepartie pour la SARL Thierry C..., dès lors qu'ils ont pour objet l'acquisition d'éléments productifs de revenus pendant une période de vingt-et-un ans ».

1525

Lorsque la cession de l'usufruit porte sur l'immeuble et non sur les titres de la SCI, il est aisé de démontrer la substance économique et juridique du schéma, aussi bien pour le cédant d'ailleurs, que pour l'entreprise cessionnaire. On sait en effet que l'absence de substance est un élément déterminant de l'existence d'un abus de droit (CE 18 février 2004, Req. n° 247729, « Sté Pléiade » : RJF 5/04, n° 510, Concl. P. Collin : BDCF 5/04, n° 65 ; CE 18 mai 2005, Req. n° 267087, « Société Sagal » : RJF 8-9/05, n° 910, concl. P. Collin BDCF 8-9/05 n° 110 ; O. Fouquet, « Abus de droit : éclaircie ? », Revue administrative, 2005, n° 347, pp. 482 et s. ; « Fraude à la loi et abus de droit », Droit fiscal 2006, n° 47, pp. 1999 et s.). Et un schéma dont la substance fait défaut devient purement artificiel et, déjà, nécessairement contraire à l'intention du législateur (P. Fernoux, « Substance, effets multiples et montage purement artificiel : une approche commune de la fraude à la loi », Droit fiscal 2008, n° 23, pp. 8 et s.).

Pour autant, démontrer la substance du montage ne présente en l'occurrence aucune difficulté. Pour le chef d'entreprise ou la SCI, la cession de l'usufruit permet la réalisation d'objectifs parfaitement défendables. Ainsi, le chef d'entreprise peut-il recueillir des disponibilités importantes, par exemple pour financer sa retraite ou réaliser un autre investissement qui, au demeurant, pourrait ensuite bénéficier à l'entreprise sous forme d'une location. En restant nu-propriétaire, il se ménage par ailleurs la possibilité de conserver à terme un patrimoine immobilier susceptible d'être transmis dans un cadre familial. Certes, il n'acquitte plus l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Son impôt diminue donc, mais quoi de plus normal ? Sa situation financière est fondamentalement différente : il ne dispose, en effet, plus des revenus correspondants. Ajoutons également que cette solution peut être fiscalement coûteuse pour lui. En effet, si à l'heure du démembrement, il a encore à supporter un emprunt lié à l'acquisition initiale de la pleine propriété, il n'est plus en droit d'imputer, sur d'éventuels revenus fonciers, les frais financiers acquittés au cours des années postérieures à celle de la cession de l'usufruit.

Par ailleurs, la solution est juridiquement intéressante *pour la société*. En détenant à son actif un droit réel d'usufruit, elle est ainsi certaine de disposer de la jouissance de l'immeuble pendant toute la durée de l'usufruit. Mieux, si, à un certain moment, elle n'en a plus personnellement l'utilité, elle peut le donner en location et recueillir les revenus locatifs, toutes choses dont elle ne bénéficie évidemment pas en qualité de locataire de l'immeuble. Elle peut également aisément adapter les locaux à sa convenance sans avoir à supporter les contraintes d'un bail commercial. Elle jouit à l'évidence d'une sécurité supérieure dans la disposition de l'immeuble.

Cette stratégie se révèle enfin performante pour elle, cette fois financièrement. Comme on l'a dit plus haut, cette solution a pour conséquence une amélioration claire, non seulement de sa trésorerie, mais également de sa marge brute d'autofinancement, en remplaçant le versement de loyers par un amortissement de l'usufruit.

Toutes ces raisons autres que fiscales attestent de la substance du schéma. Le but poursuivi n'est à l'évidence pas exclusivement fiscal. Aucun montage purement artificiel étranger aux intentions du législateur ne peut être détecté. L'abus de droit paraît donc totalement écarté à la condition, encore une fois, que l'usufruit ne soit pas évalué de manière totalement fantaisiste.

1526

Pas plus que dans la stratégie précédente, l'abus de droit ne paraît consommé lorsque la cession de l'usufruit porte sur les titres de la SCI. Il présente de l'intérêt autant pour le cédant que pour l'entreprise cessionnaire.

Le propriétaire des parts d'une SCI est en droit d'en céder l'usufruit. C'est l'exercice d'un droit fondamental ouvert à tout propriétaire. On voit mal comment l'administration pourrait revendiquer un quelconque redressement en invoquant la possibilité pour l'associé de vendre tel ou tel autre bien. Au demeurant, personne ne se poserait la question de l'abus de droit si la cession portait sur la pleine propriété des parts.

Certes, devenu nu-propriétaire des parts de la SCI, le chef d'entreprise n'acquitte plus d'impôt à raison des revenus de l'immeuble, mais là encore, il n'en dispose plus. Ils sont captés par la société exploitante du fait de la remontée des résultats dans ses propres comptes.

Il est vrai pour autant que la solution paraît fiscalement avantageuse. Lorsque les parts sont détenues par la personne physique, l'immeuble ne fait l'objet d'aucun amortissement depuis la suppression de la déduction forfaitaire de 14 % propre aux revenus fonciers. La SCI retrouve cette possibilité avec la cession de l'usufruit des parts à l'entreprise. Mais ce qui pourrait paraître un avantage excessif peut parfaitement prendre une autre figure si l'on prend la peine d'appréhender la question sous l'angle des principes gouvernant la détermination d'un revenu net. Est-il, à cet égard, contraire au principe de mettre en place un schéma qui permette l'amortissement d'un immeuble productif de revenus, alors que l'immeuble et ses composants se déprécient ? On ne le croit pas. Faute d'amortissement, cette charge n'est pas prise en compte.

Pour sa part, l'entreprise cessionnaire de l'usufruit des droits verse un loyer à la SCI, tout en amortissant par ailleurs l'usufruit des parts. Mais comment ne pas voir que la détention de l'usufruit des parts lui permet de reprendre possession d'une fraction des loyers versés ? Le résultat net de la SCI déterminé après imputation des charges sur les loyers perçus remonte en effet à la société détentrice du droit d'usufruit.

Et ce résultat net n'est pas nécessairement négatif, particulièrement lorsque la SCI a procédé au remboursement de l'intégralité de l'emprunt vraisemblablement contracté lors de l'acquisition de l'immeuble. Ce supplément de bénéfice est alors ensuite soumis à l'impôt. Le schéma peut parfaitement comporter un coût fiscal pour la société. Mais, une fois encore, si elle n'était que locataire, son résultat fiscal serait diminué en proportion des loyers versés. Sans qu'aucune compensation ne lui revienne en termes de produits.

La différence de situation est, dans ces conditions, manifeste au plan financier. Dans le même sens, l'amortissement du droit d'usufruit par l'entreprise ne constitue pas une charge réelle. Il améliore par conséquent sa capacité nette d'autofinancement.

En outre, on retrouve certains des éléments rencontrés dans la stratégie précédente. Ainsi, en disposant du droit d'usufruit sur les parts, la société opérationnelle à la certitude de pouvoir bénéficier de la disposition de l'immeuble pendant toute la durée de l'usufruit. Elle le peut d'autant plus qu'elle peut parfaitement être nommée gérante de la société. Enfin, en sa qualité d'usufruitière des parts, c'est elle qui détient le pouvoir de décision en matière d'affectation du résultat.

Ces objectifs autres que fiscaux constituent la substance du schéma et conduisent à écarter, là aussi, toute idée mise en place d'un montage purement artificiel étranger aux intentions du législateur.

D. Abus de droit (LPF art. L. 64), clause anti-abus (LPF art. L. 205 A) et mini-abus de droit (LPF art. L. 64 A)

1527

Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (op.cit. : CA Paris, pôle 5, ch.10, 3 avril 2018), comme le Conseil d'État l'a déjà jugé (CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juill. 2013, n° 356523, min. c/ SAS Garnier Choiseul Holding, n° 352989, min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding et n° 360706, min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding : Dr. fisc. 2013, n° 41, comm. 477, concl. F. Aladjidi, note F. Deboissy et G. Wicker ; RJF 11/13, n° 1064, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 883, préc. ; Dr. sociétés 2013, comm. 194, J.-L. Pierre ; Rev. adm. 2013, p. 506, obs. O. Fouquet) qu'une évolution législative avec la création de l'article L. 64 A du CGI par l'article 109 de la loi de finances 2019 (loi 2018-1317 (/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-12-28&numero=2018-1317%20&etat_initial=JORFTEXT000037882341&etat_maj=LEGITEXT000037935164)du 28 décembre 2018, art. 109 : Dr. fisc. 2019, n° 3, comm. 116, note Y. Rutschmann et P. M. Roch) n'était pas nécessaire pour que les juges apprécient le but exclusivement fiscal comme un but principalement fiscal. En effet, il est déjà exigé que l'avantage économique ou politique ne soit pas jugé « négligeable », « minime » ou « sans commune

mesure avec l'avantage fiscal tiré de ces opérations » (V. en ce sens, O. Fouquet, La réforme de l'abus de droit : pour quoi faire ? : FR 39/13, inf. 12. – F. Deboissy et G. Wicker, Rachat de sociétés « liquides » et abus de droit : le Conseil d'État écarte le motif autre que fiscal présentant un caractère négligeable et précise la finalité du régime des sociétés mères, note ss CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juill. 2013, n° 356523, min. c/ SAS Garnier Choiseul Holding, préc.).

La création de ce « mini-abus de droit » au 1er janvier 2020 peut-elle néanmoins avoir un impact sur les opérations de cession d'usufruit temporaire ? On ne le croit pas tant, les avantages économiques, politiques et patrimoniaux pour les associés de la SCI et pour la société d'exploitation qui exploite le bien et qui détient l'usufruit sont nombreux. On reste par contre bien plus circonspect lorsque l'opération est réalisée sur un bien immobilier qui n'est pas exploité par le titulaire de l'usufruit des parts sociales.

Il n'en demeure pas moins que ce nouvel article crée une insécurité juridique supplémentaire aggravée par la non-application, sous réserve d'éventuelles modifications réglementaires à venir, de la garantie prévue à l'article R. 64-1 du LPF selon laquelle la décision de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit ne peut être prise que par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Enfin, on peut légitimement s'inquiéter lorsqu'il conviendra de mettre dans la balance d'un côté une économie fiscale mesurable et de l'autre des avantages juridiques ou politiques difficilement quantifiables. Sans aller jusqu'à s'interroger, comme certains auteurs, sur une éventuelle remise en cause d'une donation en nue-propriété d'un bien immobilier à ses enfants, on peut toutefois s'inquiéter de la stratégie consistant à apporter à une SCI, sur la base d'une valeur économique et non sur la valeur fiscale de l'article 669 la nue-propriété d'un immeuble préalablement à sa transmission, dans le but non pas de limiter les droits d'enregistrement mais bien d'éviter l'indivision qui résulterait d'une donation de la nue-propriété en direct.

Enfin, et pour être exhaustif sur ce sujet, on ne peut faire abstraction dans ces schémas de la clause anti-abus générale instituée en matière d'impôt sur les sociétés introduite dans l'article 205 A du CGI par l'article 108 de la loi de finances 2019. L'article 205 A dispose que « Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents ».

Une clause de sauvegarde précise qu'un « montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

La doctrine administrative (BOFiP-IS-BASE-70-03/07/2019 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/IS/11864-PGP/2019-07-03/data.html#)) considère que « la notion de motifs commerciaux s'entend au sens large de toute justification économique, même si elle n'est pas liée à l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI. Sont donc susceptibles d'être considérées comme répondant à des motifs valables au sens de l'article 205 A du CGI des structures de détention patrimoniale, ayant des activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel. »

Là encore, il semble nécessaire de distinguer d'un côté les opérations ayant pour objectif principal de transférer les droits et les pouvoirs à travers la cession d'un usufruit temporaire portant sur les parts d'une SCI détenant un bien immobilier exploité par l'acquéreur de l'usufruit d'un schéma transférant l'usufruit des parts de la SCI à une entité ad hoc soumise à l'IS n'exploitant pas le bien détenue par la SCI. Dans cette première hypothèse, le contrôle que peut exercer l'entreprise utilisatrice à travers ses droits de vote au sein de la SCI sur le bail, son renouvellement, l'éventuelle réalisation de travaux donne à l'évidence un motif commercial valable à l'opération ; il est en effet préférable d'être usufruitier et de disposer de pouvoirs sur quinze ou vingt ans au sein de la SCI portant le bail que d'être uniquement locataire à travers un bail commercial d'une durée de neuf ans. Ce montage, pour reprendre la terminologie du législateur, répond également à des considérations patrimoniales évidentes consistant à partager dans le temps les droits, les pouvoirs et les revenus de la SCI.

Ainsi, si l'abus de droit dans sa branche relative à la fraude à la loi semble pouvoir être écarté tant au regard de l'article 205 A que de l'article L. 64 et L. 64 A nouveau du CGI, il n'en demeure pas moins qu'une opération fictive, sans substance économique réelle pour l'acquéreur ou sans intérêt patrimonial ou juridique avéré resterait susceptible de subir les sanctions de l'abus de droit. La matérialité des flux de trésorerie entre la SCI et l'usufruitier et l'existence de prérogative juridique utile à ce dernier restent les éléments clés permettant de démontrer l'intérêt économique et la substance de l'opération.

II. L'abus de droit pour fictivité

1528

La simulation ou la fictivité est à elle seule suffisante, sans même qu'il soit nécessaire de démontrer la recherche d'un objectif purement fiscal, pour que la qualification d'abus de droit puisse être retenue.

Le comité de l'abus de droit a eu à se prononcer une première fois en 2012 sur une transmission temporaire d'usufruit portant sur les titres d'une SARL détenant des biens immobiliers. Les contribuables n'ont pas cédé l'usufruit mais ont transmis celui-ci par voie de donation à leurs cinq enfants pour une durée temporaire de 5 ans. Durant cette période, le Comité relève que la société *« a été constamment déficitaire »* mais surtout que *« les donataires ont peu ou pas participé à la vie de la société dont la gestion et la conduite de la politique d'investissement demeuraient entre les mains de son gérant »*. Bien que le Comité prenne la précaution de préciser que *« la circonstance que l'usufruit temporaire ainsi constitué n'a pas été de nature à produire des fruits sur la période considérée n'établit pas à elle seule la fictivité du démembrement »*, il considère en revanche que l'ensemble des circonstances démontre que la donation n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'atténuer l'imposition au titre de l'ISF des donateurs.

Cette décision semble aller de soi tant on peut s'interroger sur l'intérêt qu'il peut y avoir à transmettre à ses enfants l'usufruit temporaire d'un bien qui ne génère sur la période transmise aucun revenu. Pour autant, c'est la fictivité du démembrement (pas de fruits et pas de participation par les usufruitiers à la gestion et à la conduite de la politique d'investissement) qui emporte la conviction du Comité.

L'abus de droit par simulation n'est pas la preuve d'une grande *virtuosité fiscale*. C'est comme le disait Maurice Cozian, *« l'abus de droit du pauvre »*. Facile à débusquer, il est également facile à sanctionner. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'affaire qu'a eu à connaître le Comité de l'abus de droit le 29 janvier 2015.

Deux frères, associés égalitairement dans une SCI, ont procédé à l'apport des titres de leur société à une nouvelle société civile, la SC J, constituée ad hoc et soumise à l'impôt sur les sociétés. L'évaluation des titres a été réalisée sur la base de l'article 669 du CGI. La société civile J ne disposait d'aucun compte bancaire, ni de trésorerie, ses revenus étaient constitués de distributions pour des montants limités représentant, dans le meilleur des cas, le montant de ses charges qui, dans les faits, étaient acquittés directement par la société civile filiale par inscription en compte. Enfin, cette société civile J n'a développé depuis sa création aucune autre activité que la seule détention temporaire de l'usufruit des titres. On aurait souhaité faire la liste de ce qu'il ne faut pas faire qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ce cas d'espèce. Lorsqu'une stratégie visant à organiser, planifier, sécuriser et optimiser sur le plan civil et fiscal la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier pour partie professionnel (jusqu'à la retraite du dirigeant) et pour partie patrimonial (après la transmission de l'entreprise) est dénaturée de la sorte et de telle manière qu'il ne reste au final qu'un montage abracadabrantesque retenant exclusivement l'intérêt fiscal, la sanction est légitime.

Le Comité n'a pas eu beaucoup de difficultés à considérer qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, en interposant la société civile J dépourvue de toute substance économique, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal.

Quel intérêt économique pour la SCI J ? Quel intérêt politique pour la SCI J ? Quel autre intérêt patrimonial, économique, politique ou juridique est-il possible de faire valoir ?

Pour autant, extrapoler cette décision à toutes les opérations de cession temporaire d'usufruit portant sur des titres d'une SCI serait pire qu'une erreur, ce serait une faute en ce qu'elle priverait les contribuables d'un choix patrimonial pertinent : ce qui a été sanctionné, c'est la fictivité du montage au cas d'espèce et non une stratégie reposant sur des motivations principalement économique, politique et patrimoniale. Le Comité, dans sa décision du 29 janvier 2015, n'a pas tué la stratégie de cession d'usufruit temporaire, elle n'a sanctionné qu'un montage sans substance, un abus de droit par simulation.

La cession de l'usufruit temporaire des parts sociales de la SCI, lorsqu'elle respecte les conditions précédentes, est une optimisation prioritairement économique, juridique et patrimoniale avant d'être fiscale. En tant que tel, l'existence d'un abus de droit fiscal ne peut donc qu'être écartée.

Chapitre IV - Les schémas à proscrire

I. La cession de la pleine propriété du bien suivi du rachat de la nue-propriété

1529

Confrontés aux dispositions de l'article 13-5° du CGI générant des coûts fiscaux très dissuasifs dans la majorité des situations, d'aucuns ont trouvé apparemment un certain plaisir à jouer les apprentis sorciers. Voici un schéma pour lequel on conseille vivement au conseil de joindre, à l'envoi de la consultation, les menottes nécessaires au client lorsque l'administration va s'en préoccuper.

Jugez-en. L'idée est la suivante. Le dirigeant cède la pleine propriété de l'immeuble à l'entreprise. Le prix est porté dans un compte courant ouvert à son nom dans la société. Jusque-là, c'est acceptable, mais la suite l'est beaucoup moins. En effet, il est proposé ensuite que l'entreprise rétrocède immédiatement la nue-propriété du même immeuble au chef d'entreprise, le prix étant acquitté par compensation au sein du compte courant. Voilà une parfaite illustration de l'absence de substance d'un montage, ou, si l'on veut, la démonstration d'une unique substance fiscale.

Il faudrait que l'administration soit particulièrement distraite pour ne pas voir que ce schéma masque, pour le moins très maladroitement, une cession de l'usufruit de l'immeuble. La meilleure preuve de cela se situe dans l'examen du compte courant. Au bout du compte, il retrace exactement le prix de cession de l'usufruit. Aucune substance économique, juridique ou financière ne vient étayer ce montage.

L'abus de droit est caractérisé et sur le fondement des dispositions de l'article 13, 5° du CGI, la valeur de l'usufruit peut parfaitement être soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et l'impôt correspondant assorti de la pénalité de 80 %. Belle journée…

II. L'apport de l'usufruit et le bénéficie du sursis de l'article 150-0 B

1530

Le même sorcier propose d'apporter l'usufruit de parts d'une SCI à une société soumise à l'impôt sur les sociétés au bénéfice du sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI. Une première remarque s'impose : dans le principe, cet apport rémunéré par la remise de parts sociales constitue bien une cession d'usufruit relevant des dispositions de l'article 13, 5° du CGI. On nous explique alors que l'article en cause ne peut recevoir application parce qu'il ne se conçoit que « par dérogation aux dispositions du présent code relative à l'imposition des plus-values ». Autrement dit, en l'absence de plus-value constatée du fait du sursis, l'article 13, 5° ne serait pas applicable. L'erreur de raisonnement est en l'occurrence frappante, comme pourrait l'être au demeurant la réaction de l'administration.

Il est vrai que l'article 150 UB du CGI énonce que la taxation immédiate au titre des plus-values est exclue dans l'hypothèse d'un apport de droits sociaux à une société soumise à l'IS. La plus-value est en effet placée en sursis d'imposition. Pour autant, prétendre que l'absence d'imposition de la plus-value immobilière au moment de l'apport fait obstacle à la mise en œuvre de l'article 13, 5° du CGI, parce qu'aucune plus-value immobilière n'est constatée relève du fantasme. Les dispositions de l'article 150 UB, II du CGI n'excluent aucunement l'apparition potentielle d'une plus-value relevant du régime des plus-values immobilières. Elles n'ont pour effet que d'en différer l'imposition par le biais du sursis d'imposition. Dans ces conditions, comme il y a bien naissance d'une plus-value de cette nature lors de l'apport. L'article 13, 5° du CGI s'applique bien, précisément par dérogation au régime des plus-values immobilières.

La meilleure preuve de l'existence d'une plus-value à la date de l'apport se trouve dans la position du Comité de l'abus de droit fiscal (Aff. n° 2013-22 : Droit fiscal 2015, n° 9, comm. 182 ; CE 27 juillet 2012, req. n° 327295, Berjot : RJF 11/12, n° 1042) dans les opérations d'apport-cession de titres à une société soumise à l'IS au bénéfice du sursis d'imposition.

Ainsi, lorsque le produit de la cession des titres apportés n'est pas réemployé dans des investissements économiques, l'apport ne peut bénéficier du sursis. L'apporteur est alors soumis à l'imposition de la plus-value au titre de l'année de l'apport. C'est d'autant plus vrai maintenant que l'apport à une société créée par l'apporteur ne bénéficie plus d'un sursis d'imposition, mais d'un report qui suppose la détermination immédiate de la plus-value objet précisément de ce report.

Pour terminer, on remarquera au demeurant que l'administration n'a même pas à recourir à l'abus de droit pour sanctionner ce type de schéma. Il lui suffit de faire le constat de l'existence potentielle d'une plus-value immobilière à la date de l'apport pour imposer le prix de l'usufruit apporté, précisément par dérogation au régime des plus-values immobilières des particuliers.

III. L'avance de fonds par la société à une filiale

1531

Il est assez fréquent qu'une société prête une partie de ses liquidités à la SCI qui va acquérir les locaux qu'elle exploitera. Cet apport en compte-courant fait parfois l'objet d'un contrat de prêt et est souvent rémunéré. Avant la loi Pacte du 22 mai 2019, les sociétés civiles ne pouvaient recevoir à titre habituel des avances en compte-courant de leurs associés que si ceux-ci détenaient au moins 5 % de leur capital (c. mon. et fin. art. L. 312-2 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072026&numero=L312-2&idspad=LEGIARTI000038611421) ancien). Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime désormais cette condition de détention du capital. Tout associé peut donc consentir une avance en compte-courant à la société, quel que soit le niveau de sa participation (loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019, art. 76, JO 23, texte n° 2). Une telle avance en compte-courant n'est-elle pas un acte anormal de gestion, un abus de bien social ou même une distribution indirecte de revenu ?

Une jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles (CAA Versailles, 3e ch., 23 octobre 2007, n° 06VE00596 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=VE&annee=06&numero=00596&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/17/98/85/CETATEXT000017988552.xml&dat10-23), Perrot) (voir annexe A4) mérite d'être citée même si celle-ci est très loin d'être pleinement approuvée par la doctrine.

M. Perrot détenait 98,8 % de la SA STIO qui avait pris une participation de 60 % dans une SCI « Les Iris », les 40 % étant détenus directement par M. Perrot. La SCI a acquis un immeuble (donné à bail à la SA) moyennant le prix de 5,9 millions de francs, financé par un apport en compte-courant de la SA à la SCI. Cet apport était rémunéré par un intérêt calculé au taux de 5 % par an.

Ce schéma est particulièrement fréquent et classique. Il a fait l'objet de nombreux commentaires par la CNCC en réponse à des Commissaires aux comptes qui s'inquiétaient d'y voir une convention interdite. La position de la CNCC est en l'occurrence parfaitement claire : il n'y a pas – en tant que tel – interposition de personne et par conséquent abus de biens social ou convention interdite :

-le fait qu'une société anonyme accorde un prêt à une SCI dont un associé est administrateur de la société anonyme ne constitue pas en lui-même une convention interdite. Il faut prouver que la SCI s'interpose entre la SA et l'administrateur, autrement dit que ce dernier est le bénéficiaire ultime du prêt (Bull. CNCC n° 45, mars 1982, p. 99, Bull. CNCC n° 92, décembre 1993, p. 540, n° 93, mars 1994, p. 129 et n° 94, juin 1994, p. 303) ;

-il s'agit d'une question de fait et la détention d'une fraction importante du capital social de la SCI ne constitue pas, en elle-même, la preuve de l'interposition de personne (Bull. CNCC n° 31, septembre 1978, p. 363 ; n° 34, juin 1979, p. 233, n° 39, septembre 1980, p. 296 ; n° 111, septembre 1998, p. 429) ;

-de même, le fait qu'une société anonyme consente un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir l'emprunt contracté par la SCI dont elle est locataire, auprès d'un organisme financier, pour l'acquisition de ses immeubles, ne constitue pas, en tant que telle, une opération interdite (Bull. CNCC n° 46, juin 1982, p. 197). Le raisonnement est identique en matière de caution (v. Bull. CNCC n° 13, mars 1974, p. 74 ; n° 39, septembre 1980, p. 341 ; n° 40, décembre 1980, p. 465).

La Cour de cassation commerciale (cass. crim. 28 septembre 2016, n° 15-87232 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CRIM.&numero=15-87232&sp=/juri/inca/global/criminelle/JURI/TEXT/00/00/33/17/64/JURITEXT000033176442.xml&date=2016-09-28)) a récemment eu l'occasion de le rappeler dans une affaire où le dirigeant était poursuivi pour abus de biens sociaux : « L'octroi par une société anonyme à une SCI d'avances de trésorerie n'est contraire à l'intérêt de la SA que, si ces avances sont dépourvues de contrepartie ; qu'au cas d'espèce, M. X... établissait que la SCI PM Investissements servait à la société PM finances, sur les sommes prêtées, un intérêt de 3 % conforme au taux de marché, de sorte que le prêt ne préjudiciait en rien à la SA ». Au cas d'espèce, la SA détenait 5 % du capital de la SCI et le prêt, accordé par la SA à la SCI sur une durée de quinze ans, avait servi à financer l'acquisition du domicile familial du dirigeant.

Pour autant, l'administration « a considéré que la société STIO avait, en finançant l'intégralité de l'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l'acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ».

La Cour considère dans cette affaire que « le requérant est devenu propriétaire, à hauteur de sa participation au capital de la société civile immobilière, de l'ensemble immobilier acquis le 29 mai 1997 sans avoir contribué personnellement au financement de cette opération ; que dès lors, et quelles que soient les modalités de financement utilisées pour la réalisation de l'opération en cause, les dépenses entièrement supportées par la société STIO pour l'achat d'un immeuble qui sera détenu à 40 % par M. X constituent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et à hauteur de cette participation, une libéralité imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué ».

Philippe Gosset et Pierre Carcelero (Option Finance, 15 juillet 2008, « Financement d'une filiale : une application surprenante de la théorie d'acte anormal de gestion ») qualifient cette décision « d'accident de jurisprudence ». Pour eux, « nous ne voyons pas comment Monsieur Perrot est devenu propriétaire sans bourse délier de 40 % de l'ensemble immobilier acquis par la société civile. En réalité, Monsieur Perrot a contribué, au même titre que la SA, au financement de cet ensemble immobilier grâce au produit tiré de la location de cet ensemble. C'est se laisser prendre à une illusion tant juridique qu'économique que d'attribuer son enrichissement à la convention de prêt litigieuse. » En outre, quelle différence pour M. Perrot si l'avance de fonds avait été réalisée par une banque et non pas sa société, STIO ?

Cette décision isolée et, à ce jour, non confirmée par d'autres jurisprudences ne doit pas alerter outre mesure. Elle rappelle cependant qu'un schéma même considéré comme usuel peut toujours encourir les foudres d'un contrôleur tatillon pour se terminer devant les tribunaux avec plus ou moins de succès. On relève au passage que la mise en place d'une opération de démembrement écarte en tout état de cause le risque soulevé dans l'affaire Perrot : le bénéficiaire effectif d'une éventuelle distribution dans cette hypothèse est l'usufruitier, la société elle-même.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.